

Droit des personnes – Droit civil. Bonifay

Le Droit civil c'est une matière à TD ¼ et cours magistral ¾ de la note.

Astrid MARAIS sur le Droit des personnes

Cours :

Le droit civil est une matière de droit privé. Tous les droits qui composent notre droit objectif se fondent sur les personnes. Le droit des personnes est un droit vivant avec des enjeux humains très important, c'est une matière qui s'intéresse aux personnes et à tous les événements de leurs vies. Elle s'intéresse aux naissances, aux décès, à l'évolution et au vieillissement de la population et on étudiera toutes les règles qui tournent autour des personnes.

Le réflexe pour chercher des définitions juridiques c'est de vérifier dans un **dictionnaire juridique**.

Bibliographie : à voir sur Ametice, si code civil : code 2022 nécessaire

1ere séance de TD : VENIR AVEC UN CODE

Plan de l'introduction :

- [Section 1 : la notion de personne](#)

Dans le langage courant, le terme personne a un sens mais, au sens juridique, la personne a un sens précis. Le droit à travers ces règles, définit ce qu'est une personne.

Paragraphe 1 : élément de définition de la personne au sens juridique :

Le terme « personne » est très utilisé par le droit et pourtant, curieusement, c'est un terme qui ne trouve pas une définition possible dans nos textes. Néanmoins, il est indispensable de savoir quel est le sens juridique de la personne car, de cette définition découlera l'application des règles de droit relative à cette catégorie. Le dictionnaire juridique de **Gérard Cornu**, définit la « **personne** » comme « ***l'être qui jouit de la personnalité juridique, c'est-à-dire, de l'aptitude à être titulaire de droit et assujetti à des obligations.*** » Donc la personne au sens juridique c'est l'être qui va jouir de droit **subjectif** (droit de vote, de propriété, du respect à la vie privé, à la protection du corps humain). Les droits subjectifs s'opposent au **Droit objectif** qui est l'ensemble des règles de droit qui régissent le rapport des individus au sein de la société (code de la route, relation de voisinage). Le Droit objectif est composé d'un certain nombre de droits subjectifs. Les droits subjectifs sont les droits que les personnes peuvent directement invoquer, dont elles sont bénéficiaires, ceux sont des prérogatives (droit au respect). La personne au sens juridique c'est celle qui jouit de ces droits subjectifs ; elle dispose de la personnalité juridique. On comprend bien que, personne juridique et personne humaine ont

deux définitions distinctes, sont deux choses différentes. La **personnalité juridique** n'est pas une qualité que l'Homme possède par nature, c'est-à-dire que c'est une création du Droit, c'est une qualité attribuée par le Droit aux personnes ; à la différence de la personne humaine, de l'être humain qui lui, n'a pas besoins du Droit pour exister. Personne juridique est donc différent de personne humaine. En Droit, au sens juridique, la personne est un sujet de Droit pour qui le Droit est construit et qui peut se prévaloir de prérogatives attribuées et sanctionnées par l'autorité publique. La personne juridique c'est la personne qui est apte à avoir un patrimoine, apte à conclure des contrats, apte à agir en justice... Alors que dans le sens courant, instinctivement, quand on pense à la « personne », on pense que cela renvoie à l'être humain. Au sens juridique, le Droit reconnaît aussi des personnes qui ne sont pas des êtres humains. En effet, il existe 2 catégories de personnes, les personnes physiques (humain) et les **personnes morales** (groupements qui vont permettre de mettre en commun des biens, des connaissances, une activité, un savoir-faire etc..., ceux sont des entités abstraites non incarnées comme les sociétés, les associations, les syndicats etc.). Ainsi tous ces groupements sont considérés comme des personnes car ils ont la personnalité juridique. C'est pourquoi les personnes morales vont avoir un patrimoine propre, un patrimoine distinct de la personne physique, elles peuvent agir en justice, et elles sont titulaires de droits et d'obligations. On distingue les personnes morales en deux catégories : les personnes morales de droit privé et de droit public. Les personnes morales de droit privé sont les entreprises, les sociétés... Pour les personnes morales de droit publics ceux sont l'Etat, les communautés territoriales... On voit bien qu'au sens juridique, la « personne » englobe plus qu'au sens commun.

Paragraphe 2 : La définition des personnes par opposition aux choses

En Droit on a une distinction majeure qu'on appelle la « **summa divisio** » une division/distinction fondamentale entre deux catégories : les personnes d'un côté et les choses de l'autre. Les personnes sont les sujets de Droit autour desquelles tout le système juridique du code civil s'organise. Le premier livre du code civil est consacré aux personnes qui disposent de droits sur des choses qui elles sont évoquées dans le livre II du code civil ; qu'elles s'échangent de différentes manières, la façon dont les personnes vont acquérir ces choses dans le livre III. Les personnes sont la catégorie principale et les choses sont la catégorie résiduelle. Tout ce qui n'entre pas dans la définition des personnes au sens du Droit, constitue pour le droit une chose. La catégorie des choses inclut tout ce qui n'est pas considéré comme une personne au sens juridique et donc elle est extrêmement hétérogène (ordinateur, embryons/cadavre, chien...). **Tout ce qui n'est pas personne est une chose. C'est la division fondamentale.** La catégorie des choses est une catégorie donc très hétérogène et il n'y a donc pas de traitement unitaire des choses et, les choses sont soumises à un régime juridique différent en fonction de sa nature. La frontière entre « personne » et « chose » peut être parfois interrogée et peu pertinente.

A- Les choses en lien avec la qualité d'être vivant

Il y a un certain nombre de « choses » au sens juridique qui bénéficient d'un statut protecteur par rapport à leur lien avec leur qualité d'être vivant.

- Premier exemple, ceux sont les embryons humains ; juridiquement, ils ne sont pas des personnes mais, bien qu'ils soient choses, les embryons bénéficient d'un statut protecteur en leur qualité d'être humain.

- Les enfants nés sans vie, c'est-à-dire un enfant qui est mort-né. Il est né sans vie donc n'a pas la personnalité juridique mais, il bénéficie d'une protection.

- Le cadavre humain, après le décès, le corps humain n'est plus une personne au sens juridique, néanmoins, il possède une protection et n'est pas traité de façon ordinaire comme toutes les autres choses. **L'article 16-1-1 « le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort, les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation doivent être traités avec respect, dignité et décence. »**

- Les animaux traditionnellement relèvent de la catégorie des choses mais, depuis la loi du 16 février 2015, l'article 515-14 du code civil précise désormais que : « **Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité** ». Cet article ajoute que « **sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.** » Ils restent donc des choses mais ne sont pas ordinaires, ils ont un régime juridique spécifique. Exemple : **arrêt du 9 décembre 2015 Cours de Cassation, 1ère Chambre civile** : une personne achetée un chien de race en animal de compagnie et, il s'est trouvé que le chien avait des problèmes de vue qui occasionné pour le propriétaire des problèmes de soins onéreux. Il est alors allé voir l'éleveur qui lui a vendu et demande un dédommagement pour prendre en charge une partie des soins et l'éleveur lui a proposé un remplacement. En droit de consommation, cela est possible. La question qui s'est posée c'est : est-ce que pour un chien cela peut se réaliser ? Ne voulant pas qu'on le lui remplace, elle est allée en justice et les juges ont considéré qu'en effet, « **le chien en cause était un être vivant unique et irremplaçable et un animal de compagnie destiné à recevoir l'affection de son maître sans aucune vocation économique** ». Le remplacement était donc inenvisageable et il fallait privilégier un dédommagement pour prendre en compte la qualité d'être vivant du chien.

Ces différentes catégories de choses ne sont pas titulaires de droits subjectifs, ne sont pas des personnes au sens juridique mais, en tant qu'êtres vivants ou ex-vivants, ils doivent être respectés, protégés par rapports aux choses qui sont classiques. Ce régime protecteur démontre que la frontière entre les personnes et les choses méritent parfois d'être relativisée et nuancée.

B- Les robots et les machines intelligentes

Un robot est une machine capable d'exercer certaines choses programmées. Aujourd'hui, le développement de l'intelligence artificielle est très important et, on constate dans tous les secteurs, tous les environnements la présence de ces derniers. Cette intelligence se développe toujours plus et, plus elle se développe, plus les juristes se questionnent. Plus ces robots vont être perfectionnés et autonomes, plus ils vont se rapprocher des êtres humains, plus la question de leur statut, de leur responsabilité va se poser. Par exemple, à Hong Kong, une société a créé Sophia, un robot humanoïde depuis 2015 et qui est programmé à tout apprendre en s'habituant aux comportements des Hommes. En 2017, Sophia a même acquis une nationalité alors que par principe, la nationalité est donnée qu'à des personnes au sens

juridique. Le parlement européen se questionne aussi et, en 2017 il a adopté une résolution avec des recommandations concernant des règles de droit civil sur la robotique. Elle propose à terme la création d'une personnalité juridique spécifique pour les robots. Beaucoup d'auteurs soulèvent le fait que cela peut paraître absurde mais, dans tous les cas, ce genre de textes nous questionnent sur le développement de l'intelligence artificielle et sur toutes les retombées juridiques. Le Droit bouge, il est mouvant en fonction de ces avancées, de l'opinion publique, il est influencé par de nombreux secteurs sociaux, économiques.

- Section 2 : L'évolution du Droit civil des personnes

Pendant longtemps, la personne était appréhendée dans sa sphère sociale, publique et collective, c'est-à-dire que ce qui comptait était le rôle de l'individu dans la vie juridique, sociale et non pas dans sa vie personnelle, individuelle. C'était sur l'individu acteur dans la vie commune. Au fil de l'histoire, on est allé vers une **individualisation de la personne** qui s'est faite en 2 étapes :

- Passage vers la liberté et l'égalité. En effet, autrefois, dans l'antiquité, la notion de personne était divisée entre la personne libre et la personne non-libre (esclave). En droit romain, l'esclave appartenait à son maître, faisait partie de son patrimoine comme les autres biens, ce qui permettait de les vendre. Néanmoins, le droit les considérait comme des personnes juridiques mais non libre ; pas des choses. C'est seulement dans la **Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789** proclame dans son **article 1** : « **Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux.** »

- La reconnaissance de la personne en tant qu'individu doté d'une âme et d'un corps. En **1804** le code civil appréhendait encore l'individu comme une personne qui compose la société, il n'était pas appréhendé dans sa sphère privée. Le lien avec l'être humain s'est resserré progressivement, on a pris de plus en plus en compte la corporéité de la personne et aujourd'hui, le code civil s'attache à la protection et au respect de la personne physique, à la fois son intégrité morale, et son intégrité physique. D'où ce mouvement d'individualisation. S'agissant de l'intégrité morale, la jurisprudence a, au cours du XXe siècle, développé ce qu'on appelle les droits de la personnalité, qui sont des droits qui visent à protéger l'intégrité morale des personnes, donc leur vie privée, leur honneur, leur réputation etc. C'est particulièrement la **loi du 17 juillet 1970** qui est venu consacrer cette évolution jurisprudentielle en venant ajouter un **article 9** sur le droit de la vie privée. S'agissant de l'intégrité physique, le mouvement a été un peu plus tardif car c'est à la fin du XXe, face aux progrès des techniques médicales et scientifiques, que l'on a pris conscience à quel point certaines techniques pouvaient venir porter atteinte au corps humain et à l'espèce humaine. Quand on a pris conscience par exemple du clonage, des incidences que cela pouvait avoir sur le corps humain, le législateur a adopté les premières **lois de bioéthiques** le **29 juillet 1994** qui ont consacré un principe de protection de l'intégrité physique des personnes. Ces lois bioéthiques ont reconnu de nouveaux droits subjectifs au profit des personnes comme le « **droit à la dignité et au respect de l'être humain dès le commencement de sa vie** », dans l'**article 16** de la bioéthique, le droit à l'**intégrité du corps humain** dans l'**article 16-3**. Depuis l'introduction de ces principes, les

lois bioéthiques ont fait l'objet de révisions régulières, par exemple le 6 août 2004 qui a ajouté le respect de l'intégrité de l'espèce humaine dans l'article 16-4, puis en 2011 et le 2 août 2021. Ces lois bioéthiques évoluent au fil du temps et il y a même l'obligation de les faire évoluer (inscrit dans la loi). Ces règles bioéthiques permettent de délimiter les droits que chacun peut avoir ou non sur son propre corps et elles nous interrogent sur certaines techniques, sur la façon de réglementer juridiquement certaines questions. Les thématiques de la bioéthique sont par exemple la question d'euthanasie, le don d'organe, les expérimentations sur le corps humain...

- Section 3 : Les sources du Droit des personnes.

La source principale du droit des personnes est évidemment le code civil mais il y en a d'autres. Quand on parle de source, ça veut dire

A- D'autres codes que le code civil

- Le code des sociétés
- Le code de la santé publique (CSP) qui regroupe toutes les règles relatives au corps humain, à l'accès à la PMA, au don d'organe, ou encore les règles relatives à l'interruption de grossesses. Certains articles du code de la santé publique sont reproduits dans le code civil. Dans celui-ci à la suite de l'article 16-, il y a un extrait du CSP pour permettre aux juristes d'avoir l'avis général puis simplifié
- Le code pénal est une source du droit des personnes car on y retrouve toutes les règles relatives aux atteintes qui peuvent être portées à l'intégrité des personnes, des règles d'état civil, les infractions relatives à la personnalité comme la violation de la vie privée ou encore, les dispositions relatives aux atteintes à la dignité de la personne comme les discriminations.

B- Dans des lois

Certaines lois importantes n'ont pas été codifiées, c'est-à-dire que leur contenu, n'a pas directement été intégré dans des articles de codes existants. Des lois viennent modifier des articles ou en ajouter aux codes mais certaines viennent juste préciser une règle, la poser et cela sans qu'elle soit dans l'article d'un code : pas codifiées. Par exemple, les **lois du 28 juillet 1881 sur la liberté de la presse** ne sont pas des lois codifiées mais on peut les mobiliser devant le juge et les invoquer. A la fin du code civil, il y a une table des lois non codifiées.

C- Des textes à valeur constitutionnelle

Il y a plusieurs textes à valeur constitutionnelle qui comportent des règles de droit des personnes. Il y a le bloc de constitutionnalité c'est-à-dire un ensemble de textes qui ont une valeur plus importante que les autres droits. Ce bloc est au sommet de la hiérarchie des normes et tous les textes qui sont en dessous doivent être conformes à ce bloc. Par exemple, la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 est un texte à valeur constitutionnelle ou le préambule de la constitution de 1804 qui soulèvent des principes des droits des personnes. On peut citer des **PFRLR** qui sont les **P**rinces **F**ondamentaux **R**econnus

par les Lois de la République où il y a par exemple la liberté d'association, les droits de la défense, la liberté de conscience ; ceux sont aussi des principes de sources du droit des personnes à valeurs constitutionnelle. En raison de l'existence de ces textes constitutionnels, la jurisprudence du Conseil Constitutionnel est aussi une source du Droit des personnes, surtout depuis l'instauration de la QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, qui permet, pendant une action en justice d'invoquer devant le juge la non-constitutionnalité ou la non-conformité à la constitution d'une disposition législative. La loi est en dessous des textes de constitutionnalité et les règlements sous en dessous de la loi : le plus bas de la pyramide doit être conforme à tout ce qui se trouve au-dessus. Plusieurs QPC ont pu être soumises ces dernières années concernant le droit des personnes, par exemple : l'**article 16-11 alinéa 2 du code civil** prévoit que « *Sauf un accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreinte génétique ne peut être réalisée après sa mort* » : on ne peut pas faire de test génétique (ex : ADN) sur une personne décédée sur un cadavre si l'a personne lors de son vivant ne l'a pas acquiescé. Le but de cette disposition introduite en 2004 a été de clore un débat qui avait été ouvert après le décès d'Yves Montant décédé en 1991 ; une jeune femme se prétendait être sa fille et avait agis en justice pour faire reconnaître le lien avec l'artiste. Les héritiers d'Yves Montant avaient demandés un test ADN pour vérifier que ce soit la fille. Cela s'est réalisé mais l'opinion publique semble choquée ; l'article est donc modifié en 2004 avec l'article 16-11. En 2011, le conseil constitutionnel a été saisi dans une autre affaire dans laquelle des requérants invoquaient que cette disposition qui interdit les prélèvements post mortem n'était pas conforme à la constitution car contraire au droit et au respect de la vie privée et la connaissance de ses origines ; le conseil a statué et déclare que cette disposition est bien conforme avec la constitutionnalité.

D- Des textes supranationaux

Notre droit est composé de sources nationales, c'est-à-dire internes mais aussi de textes internationaux c'est à dire supra nationales comme le texte fondamental : la **convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de liberté fondamentale**, signé en 1950 et ratifié en 1974 par la France. Ce texte a été adopté dans le conseil de l'Europe (différent de l'Union Européenne). La CEDH comprend un ensemble de droits liés aux personnes (**article 8 : le respect de la vie privée familiale/ l'égalité des époux, l'article 12 : la liberté de mariage**). La Convention Européenne pose des droits et libertés pour les personnes mais, son efficience est en réalité assurée surtout grâce à la **jurisprudence** (l'ensemble des décisions) de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, donc par les états. Cette cour est chargée de la disposition de la convention et la bonne interprétation de l'ensemble des décisions. La Cour européenne a bâti une jurisprudence riche et évolutive notamment fondé sur l'article 8, et cette jurisprudence est à l'origine de nombreuses évolutions de notre droit civil. Les jurisprudences de la CEDH exercent une influence importante sur notre Droit des personnes parce qu'on a plusieurs exemples où à la suite d'une condamnation de la Cour européenne, on a fait évoluer nos droits. Par exemple, la question du changement de sexe à l'état civil, le droit français a évolué notamment après avoir été condamné par la cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 8, en effet selon la CEDH, cela porté atteinte au droit à la vie privé et à son respect. Une condamnation par cette cour incite les états à faire évoluer leurs droits. Sur la question plus récemment de la gestation sur autrui, la France a été condamné en 2014

par la Cour Européenne des droits de l'homme car, elle refusé de transcrire sur les registres d'Etat civil français le lien de filiation des enfants qui été nés à la suite d'une gestation (faire appel à une mère porteuse) pour autrui à l'étranger. Comment doit-on réagir quand un couple a fait appel à une gestation à l'étranger ? Première réponse : non, puis après la condamnation a modifié son droit. Quand la Cour européenne condamne un état sur une question, il modifie son droit pour avoir une législation qui est conforme à la Cour européenne car il a accepté la Convention.

- Section 4 : les fonctions du Droit des personnes

Le **droit des personnes** remplit un **double rôle** à l'égard des personnes. Dans le **premier rôle**, il **institue les personnes**, c'est-à-dire que, le droit des personnes **définit** qui est une personne au sens juridique, permet de lui donner sa place dans la société et de lui reconnaître une résistance propre et individuelle. Et c'est à cette fonction que répondent les règles sur par exemple l'attribution de la personnalité juridique, mais aussi les règles qui permettent d'identifier les personnes (relatif à l'identité). Dans sa **seconde fonction**, le **Droit civil protège les personnes**, que ce soit leur intégrité morale ou physique. Néanmoins, le Droit des personnes **protège** aussi plus particulièrement certaines catégories de personnes qui sont dites **personnes vulnérables**. Les droits de la personne vulnérable concernent les plus jeunes, les plus âgés et toutes les personnes qui en raison de leur état physique ou mental, ne sont pas aptes à agir par eux-mêmes sur la scène juridique. Est-ce que la personnalité est acquise pour toute la vie (ex : coma etc.) ? oui, on l'acquiert de la naissance jusqu'au décès. Cependant on pourra plus ou moins être protégés par le droit comme les tutelles etc. pour les personnes qui ont besoins d'être assistées.

Thème 1 : la personnalité juridique

Tous les différents droits qu'on a pu lister dans l'introduction comme la protection de l'intégrité physique ou morale, tous ces droits peuvent être revendiqués par ce que l'on appelle des Sujets de Droit, des personnes au sens juridique. La **personnalité juridique** c'est une notion abstraite, c'est l'aptitude à être Sujet de Droit, à être titulaire de Droit et d'obligation. Ont la personnalité juridique 2 catégories de personnes : les personnes physiques et les personnes morales. Ce premier thème sera dédié à la personnalité juridique des personnes physiques. C'est-à-dire qu'on va étudier à quelle condition la personnalité juridique est attribué aux individus. Premier élément, chaque être humain qui né vivant et viable se trouve doté de la personnalité juridique, c'est-à-dire qu'il est apte à être sujet de Droit et d'obligation sans aucune distinction.

Section 1 : L'acquisition de la personnalité juridique

La personne juridique se superpose à la personne humaine donc, le début et la fin de la vie humaine sont les bornes temporelles de l'acquisition et de l'extinction de la personnalité juridique. Mais la question se pose alors de savoir, **quand commence la vie humaine** ? La science peut répondre à cette question : la vie humaine commence dès la fécondation donc, dès que 2 personnes fusionnent pour créer une vie humaine. Mais, pour le droit, ce n'est pas ce commencement de vie humaine qui détermine l'acquisition de la personnalité juridique ; **c'est la naissance.**

Paragraphe 1 : le moment de l'acquisition de la personnalité juridique : la naissance

L'acquisition de la personnalité juridique est marquée par un **principe de simultanéité**, c'est-à-dire que, l'individu accède à la personnalité juridique **à l'instant même où il né**. Ce qui distingue bien la naissance de la procréation. La naissance d'un enfant qui, concrètement fait suite à l'accouchement de la mère, constitue un fait juridique auquel la loi attache des conséquences juridiques à savoir l'attribution de la personnalité juridique

A- Les formalités liées à la naissance

La première formalité est la déclaration de naissance ; toute nouvelle personne doit être rapidement connue par l'Etat, ce qui conditionne l'attribution d'un état civil. Toute naissance doit être déclarée dans la mairie du lieu d'accouchement sous 5 jours qui suivent l'accouchement ; c'est **l'article 55 du code civil**. Cette déclaration est très importante, c'est une obligation car elle conditionne l'obtention d'un état civil et c'est pourquoi la déclaration de naissance est une obligation légale. **L'article 433-18-1 du code pénal** sanctionne le **fait de ne pas déclarer une naissance à l'Etat civil**. C'est pourquoi, en pratique, les maternités sont très vigilantes, bien souvent, elles demandent avant de sortir de la clinique qu'on leur remette un récépissé de déclaration à l'Etat civil des enfants nés dans la naissance. Grâce à la déclaration de naissance, l'officier d'Etat civil va dresser l'acte de naissance qui comporte un certain nombre de mentions obligatoires qui sont listées à **l'article 57 du code civil**.

B- Les conditions pour que la naissance entraîne l'acquisition de la personnalité juridique

Le principe est, que toutes personnes acquièrent de façon automatique à sa naissance la personnalité juridique mais, il y a **deux conditions** pour cela : **l'enfant** doit naître **vivant** et **viable**. Les enfants mort-nés, c'est-à-dire qui naissent déjà morts, sans vie, n'accèdent pas à la personnalité juridique, ils n'auront pas été considérés comme des personnes. Sur la condition de vie, un enfant est considéré comme **né vivant**, lorsqu'à **la naissance il respire**. La **viabilité** est plus complexe, en effet, on peut la définir comme la capacité naturelle de vivre, c'est **l'aptitude à la vie**, c'est-à-dire que, l'enfant viable c'est celui qui est physiologiquement capable de survivre. Cette notion de viabilité a été précisée par une **circulaire du 22 juillet 1993**, cette circulaire précise que **conformément aux recommandations de l'OMS** (l'Organisation Mondiale de la Santé), **les enfants pesant aux moins 500 grammes ou nés après 22 semaines d'aménorrhée** (absences de règles durant la grossesse) **sont présumés viables indépendamment de tout autre critère**. De même, tout enfant qui est né vivant est présumé viable même s'il meurt peu de temps après. Néanmoins, c'est une présomption qui n'est donc pas indéfendable, on peut montrer qu'il n'était pas viable pour qu'il n'ait pas accès à la personnalité juridique. L'enfant qui né vivant et viable devient juridiquement une personne, il acquiert la personnalité juridique donc, un statut juridique, il a une identité, un nom et des droits patrimoniaux ou extrapatrimoniaux. A contrario, l'enfant simplement conçu, c'est-à-dire encore dans le ventre de la mère, et l'enfant sans vie, n'ont pas la personnalité juridique.

C- Quel statut pour l'enfant né sans vie ? Qui est-il ? Quel est son statut juridique ?

N'ayant pas la personnalité juridique l'enfant mort-né ne peut être titulaire de droits subjectifs et on comprend que cette situation soit difficilement vécue par les proches. Pour prendre en compte ces situations et pour permettre aux parents de faire leur deuil, **la loi du 8 janvier 1993 a créé l'acte d'enfance en vie qui est prévu à l'article 79-1 alinéa 2 du code civil**. Cet article, dans son premier alinéa, il prévoit l'hypothèse des enfants qui naissent vivants mais qui décèdent rapidement, avant qu'on ait réalisé leur déclaration à l'Etat civil (l'enfant né à 8h et décède à 14h). Le premier alinéa nous dit l'officier d'Etat civil va établir 2 actes : d'abord un acte de naissance puis, un acte de décès car, l'enfant est né vivant, il a eu quelques heures la personnalité juridique. En revanche, l'alinéa 2 concerne l'acte d'enfant né sans vie. Cet alinéa précise que, sans le certificat médical justifiant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier d'Etat civil établit un acte d'enfant sans vie. Les conséquences de cet acte sont que, l'acte va être inscrit que les registres de décès et va entraîner certaines conséquences juridiques comme le fait que les parents vont pouvoir donner à l'enfant 1 ou plusieurs prénoms (pas de nom car cela nécessite de personnalité juridique), l'enfant va pouvoir figurer sur le livret de famille des parents ce qui est symbolique. Cet acte va aussi ouvrir à des droits sociaux comme les congés de maternité et paternité. L'acte d'enfant sans vie permet aux parents de réclamer le corps de l'enfant pour pouvoir organiser des funérailles. Ces droits peuvent paraître symboliques mais, c'est un embryon de dispositions pour prendre en compte la vie qui a existée.

Paragraphe 2 : l'atténuation du principe d'acquisition de la personnalité juridique à la naissance : des droits et une protection, accordés avant la naissance.

Avant la naissance, l'enfant ne se voit pas reconnaître de personnalité juridique, sauf quelques exceptions mais, avant la naissance, il y a des textes spécifiques qui protègent l'embryon.

A- L'absence de personnalité juridique avant la naissance mais une protection relative.

L'embryon et le fœtus sont protégés en tant qu'êtres humains mais, la protection pénale est très relative.

1. Une protection sous la qualification d'être humain.

La question du statut juridique de l'enfant in utero (dans l'utérus), c'est une question qui a toujours été très discutée et qui l'est d'ailleurs toujours. Le terme embryon fait référence à l'être humain au premier stade de son développement c'est-à-dire jusqu'à 8 semaines ; au-delà, on parle de fœtus. L'embryon et le fœtus sont protégés non pas en tant que personnes mais en tant qu'êtres humains.

- *Les textes qui protègent l'embryon : l'article 16 du code civil* qui dispose « **La loi garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie** ». Cet article a été inséré dans notre code en 1994 par l'une des trois lois bioéthiques. Il faut bien distinguer les termes, en effet, l'être humain (et non la personne), englobe l'enfant simplement conçu qui n'est pas encore né donc qui n'a pas encore acquis la personnalité juridique, il est encore in utero et ; il doit être respecté dès le commencement de sa vie. Cet article 16 pose un principe général de protection de la vie humaine qui inclut la vie humaine prénatale. Dans le code de la santé publique, on retrouve beaucoup de dispositions et d'articles qui concernent l'embryons et qui le protègent. Ces règles rappellent que, la conception d'embryons par des techniques médicales est strictement encadrée et qu'elle n'est permise que dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation pour un couple ou une personne seule (femme seule depuis août 2021) qui poursuit un projet parental. Pour l'illustrer, **l'article I2141-3 du code de la Santé publique, alinéa 1 : « Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation définie à l'article L. 2141-1. »**. La conséquence de cette disposition est qu'il est interdit de concevoir des embryons à des fins de recherches, c'est **l'article I2151-2 du Code de la Santé Publique** ; il est également interdit de créer des embryons à des fins industrielles ou commerciales, écrit dans **l'article I2151-3** mais également **l'article 311-20 du code civil**. Ce respect qui est dû à l'embryon n'est pas absolu car, il est parfois confronté à d'autres intérêts, notamment ceux de la femme qui porte l'embryon, et ceux de la recherche scientifique.

- *Les limites de la protection de l'embryon* : des atteintes peuvent être portées à l'embryon. Premier exemple, l'interruption de grossesse, depuis la **loi Veil du 17 janvier 1975**, le **droit français autorise l'interruption de grossesse** si, **l'état de grossesse place la femme dans une situation de détresse physique ou morale**. La femme peut décider d'interrompre sa grossesse de façon discrétionnaire jusqu'à 12 semaines de grossesse, c'est **l'article I2212-1** ; et au-delà de 12 semaines, l'interruption de grossesse est toujours possible, seulement si la grossesse met en péril grave la santé de la mère ou, s'il existe une forte probabilité que

l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ; on est alors à une interruption médicale (pas une interruption volontaire comme avant (IVG)). Le deuxième exemple des limites de la protection de l'embryon est la possibilité de « détruire » des embryons dans le cadre d'une expérience médicale à la procréation. Les lois de bioéthiques ont permis la « destruction » des embryons surnuméraires lorsqu'ils ne font plus l'objet d'un projet parental, c'est **l'article l2141-4 du code de la Santé publique** qui le prévoit car cet article précise que, « ***les membres du couple dont les embryons sont conservés peuvent s'ils n'ont plus de projet parental, demander la fin de la conservation de leurs embryons*** ». Concrètement, lorsqu'un couple ou une femme non mariée font appel à un processus de procréation assistée avec une fécondation in vitro, plusieurs embryons sont créés pour avoir plus de chance et les médecins les inséminent mais il peut en rester en dehors. Les embryons restants sont donc conservés pour pouvoir avoir d'autres enfants plus tard par exemple (environ 200 000 en 2010). Le choix vient alors au couple de la conservation ou non de ces derniers. Ils peuvent le garder, le donner à la science ou à d'autres parents. Le principe de la protection de l'embryon est alors relativisé car les parents ont le droit de vie ou de mort de l'embryon. A ce sujet, le conseil constitutionnel a considéré dans une **décision du 27 juillet 1994**, que le principe posé à l'article 16 du code civil, pouvait valablement ne pas concerner l'embryon fécondé in vitro et c'est pourquoi les lois bioéthiques de 1994, ont été jugées constitutionnelles. Le troisième exemple des limites est l'utilisation des embryons à des fins de recherches scientifiques. De la même façon, le couple n'ayant plus de projet parental peut décider de donner ses embryons pour qu'ils fassent l'objet de recherches scientifiques. Au titre de l'évolution des recherches, il faut savoir qu'en **1994 lors des lois bioéthiques**, il y avait un **principe d'interdiction de toutes formes d'expérimentations sur l'embryons**. Puis, en **2004**, les lois bioéthiques ont été modifiées et le principe a été maintenu mais on a permis à titre exceptionnel des recherches sur l'embryons. La **loi du 16 juillet 2013** a inversé le principe et a donc transformé le principe d'interdiction des recherches sur l'embryon en un principe d'autorisation de ces recherches, on voit que le raisonnement change. Aujourd'hui, c'est l'article **l2151-5 paragraphe 1 du Code de la santé publique** qui **permet que des recherches scientifiques soient menées sur des embryons** surnuméraires ou, que des cellules dérivées de ces embryons soient utilisées dans une préparation de thérapie cellulaire ou dans un médicament de thérapie innovante à des fins exclusivement thérapeutiques. Ces cellules dérivées de ces embryons sont prélevées sur l'embryon entre 5 et 7 jours après sa création. On autorise les recherches mais elles restent très encadrées puisque les textes prévoient qu'elles doivent avoir une finalité médicale, il faut démontrer la pertinence scientifique de la recherche et il faut démontrer aussi que la recherche ne peut pas être menée par un autre moyen que par l'utilisation d'embryons. Au titre des conditions, ces recherches ne peuvent être menées que sur des embryons conçus in vitro donc dans le cadre d'un PMA, embryons pour lesquels il n'y a plus de projet parental et évidemment, le couple qui est à l'origine doit avoir donné son consentement. Depuis la **loi du 2 août 2021**, il y a eu des ajouts à la loi bioéthique, on a fixé une **limite de 14 jours la culture des embryons humains sur lesquels on peut réaliser ses recherches**.

2. Les conséquences d'un point de vue pénal de l'absence de personnalité juridiques avant la naissance

Du point de vue du droit pénal, l'enfant à naître n'ayant pas la personnalité juridique, le droit pénal français ne reconnaît pas l'incrimination d'homicide involontaire sur le fœtus dès lors qu'il n'est pas né vivant et viable. Cette **solution**, ce principe a été affirmé dans un arrêt rendu par la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière (totalité de l'assemblée => arrêt très important) **le 29 juin 2001**. Dans cette décision, il s'agissait d'une femme enceinte de 8 mois qui est victime d'un accident de la route à cause d'un chauffeur de camion qui conduit en état d'ivresse, la mère survit mais le fœtus décède. En droit pénal, **l'article 221-6 du code pénal**, réprime **l'homicide involontaire qui est défini comme « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »**. La Cour de cassation a tranché, l'article n'est pas applicable au fœtus, autrement dit, la Cour de cassation écarte l'homicide involontaire sur un fœtus décédé in utero. La cour européenne a été questionnée à ce sujet et elle a considéré que l'Etat du droit français sur cette question ne contrevient (contraire à) pas à **l'article 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui protège le droit à la vie**. Selon la Cour européenne, le texte est silencieux sur les limites temporelles de ce droit, et, selon elle, chaque état dispose d'une marge d'appréciation pour répondre à la question de savoir si l'enfant à naître est une personne ou non au sens de l'article 2 de la CEDH. Cette décision est un **arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 8 juillet 2004, c'est l'arrêt Vo contre France**. Bien qu'il n'y ait pas de protection du fœtus contre l'homicide involontaire, il y a des infractions spécifiques qui existent en cas d'atteinte du fœtus contre la volonté de la mère comme **l'article 223-10 du code pénal qui va permettre de protéger la femme enceinte mais pas le fœtus**.

B- L'exception : l'adage (expression lapidaire issue de la tradition juridique, énonçant, sous une forme concise et frappante, une règle de droit, une sentence morale ou un fait d'expérience) **infans conceptus (l'enfant conçu)**

1. L'énoncé de la règle

L'adage infans conceptus est une fiction selon laquelle l'enfant simplement conçu va être considéré comme étant déjà né chaque fois qu'il en va de son intérêt. C'est une règle qui a été énoncée par l'ancien Droit (c'est-à-dire le droit applicable jusqu'à la Révolution française) et qui, d'après certains auteurs, se retrouvent de façon implicite dans 2 articles du **code civil** qui sont les articles **725** et **906**. **L'article 725** précise quelles sont les qualités requises pour pouvoir succéder, pour pouvoir recevoir une succession ; il précise que, ***pour succéder*** (recevoir une succession), ***il faut exister au moment de l'ouverture de la succession*** ou ***« ayant déjà été conçu, naître viable »***. **L'article 906** est plus explicite, il précise ***que pour recevoir une***

donation (du vivant de la personne contrairement à lorsqu'il est mort), **il suffit d'être conçu au moment de la donation mais l'article ajoute que, la donation n'aura d'effet qu'au temps que l'enfant sera né viable**. Cet adage a ensuite été repris par la jurisprudence pour l'étendre et cet adage a été érigé en principe général de droit par la Cour de cassation dans une **décision du 10 décembre 1985**. Cette règle signifie que l'enfant simplement conçu peut bénéficier d'une personnalité juridique anticipée s'il en va de son intérêt et à condition qu'à terme il naisse vivant et viable c'est-à-dire que, s'il né vivant et viable, l'enfant peut se voir ouvrir de manière rétroactive des droits dès l'instant de sa conception.

2. Les conditions de l'infans conceptus

Pour que l'adage infans conceptus s'applique, et pour que l'enfant bénéficie de la personnalité juridique de façon rétroactive à sa conception, il y a plusieurs conditions qui doivent être réunies :

- **L'intérêt de l'enfant** : il faut qu'il y trouve un intérêt. Par exemple, ce sera le cas de l'enfant simplement conçu qui n'est pas encore né, dont le père décède au cours de la grossesse. L'enfant peut par exemple obtenir réparation de son préjudice moral alors que pourtant, il n'était pas né au moment de l'accident à l'origine du décès de son père, pourtant, il n'était pas né au moment du fait générateur de responsabilité. La 2^e chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2017 avec comme numéro de pourvoi, le numéro 16-26.687 : il faut que l'enfant ait intérêt à bénéficier de la personnalité juridique.
- **L'existence d'un enfant conçu** : il faut que l'enfant ait été conçu au moment auquel on voudrait qu'il ait eu la personnalité juridique. La date de la conception d'un enfant, scientifiquement, elle est difficile à déterminer avec certitude. **L'article 311 du Code Civil**, pose une présomption selon laquelle l'enfant est **présumé** avoir été **conçu** au cours d'une période qui s'étend du **300^e jour au 180^e jour inclus, avant sa naissance**.
- **La naissance d'un enfant vivant et viable**. Il faut que l'enfant vienne au monde vivant et viable. S'il né bien vivant et viable, il accède à la personnalité juridique, qui peut rétroagir si les 2 autres conditions citées précédemment sont acquises.

Un individu décède dans un accident du travail alors que sa femme est enceinte. Peu de temps après l'enfant né vivant et viable, la mère va intenter une action en justice pour demander réparation de son propre préjudice moral, mais l'adage infans conceptus va lui permettre de demander aussi réparation du préjudice moral de son enfant pour le compte de son fils, alors même qu'il n'était pas encore né au moment de l'accident (et donc, qu'il n'avait pas encore une personnalité juridique confirmée au moment de l'accident. Dans cet exemple, les 3 conditions sont remplies : la condition d'intérêt de l'enfant car il a intérêt à bénéficier une personnalité juridique anticipée qui agit de manière rétroactive pour bénéficier à réparation ; la deuxième condition est remplie aussi, cet enfant était déjà bien conçu et enfin, l'enfant est né vivant et viable donc il a accédé à la personnalité juridique, qui a rétroagit après sa naissance). Un fœtus n'a pas la personnalité juridique, il a la capacité à l'avoir mais c'est seulement lorsqu'il est né vivant et viable qu'il l'a.

Pour résumer, en Droit français, la personnalité juridique s'acquiert à la naissance à condition que l'enfant naisse vivant et viable ; si l'enfant né vivant et viable, l'acquisition de la personnalité juridique peut, s'il en va de son intérêt, rétroagir au jour de sa conception qui est présumée avoir eu lieu durant la période allant de 300^e au 180^e jour inclus avant sa naissance. Si l'enfant ne né pas vivant et viable, la personnalité juridique est censée n'avoir jamais existée. Tout au long de la conception, le fœtus a une personnalité juridique, en germe mais pas acquise.

- Section 2 : la fin/l'extinction de la personnalité juridique

La personnalité juridique est conservée jusqu'à son décès. Il y a des cas où la mort est certaine, mais quelquefois, il y a des conditions sur la date de l'extinction.

Paragraphe 1 : La mort

La personnalité juridique cesse avec le décès, puisque la personne humaine voit sa vie prendre fin.

A- Les formalités liées au décès

Le décès a d'importants effets juridiques, il faut donc déterminer avec certitude la date du décès. Evidemment, il y a des situations dans lesquelles le décès ne fait pas de doute, c'est l'hypothèse où on retrouve un corps inanimé, le cœur ne bat plus et le corps représente toutes les caractéristiques d'un corps décédé comme la rigidité cadavérique. Le moment du décès est donc le moment où on trouve la personne décédée. Dans d'autres hypothèse, le constat de la mort est plus délicat à établir, par exemple lorsqu'une personne est victime d'un arrêt cardiaque ; autre fois on considèrerait que l'arrêt du cœur était le critère du décès. Aujourd'hui, par rapport aux progrès de la médecine, on sait qu'il est possible de faire repartir le cœur dans les minutes qui suivent son arrêt, sans que les fonctions vitales soit atteintes. C'est pourquoi aujourd'hui, on détermine la mort en fonction de la mort cérébrale, c'est-à-dire la mort du cerveau. Aujourd'hui, seul un diagnostic de mort cérébrale permet le prélèvement d'organe. Une fois qu'il est constaté, le décès fait l'objet d'un certificat médical qui va permettre de procéder aux funérailles et, ce décès va être rendu public par la rédaction d'un acte de décès. Tout décès doit être rendus publics par la rédaction d'un acte de décès établi par l'officier d'état civil de la commune dans laquelle le décès a eu lieu, après qu'il ait été déclaré par toutes personnes qui peut en faire la déclaration. L'acte de décès est ensuite diffusé, c'est-à-dire qu'il en est fait mention en marge de l'acte de naissance du défunt. Le décès entraîne l'extinction de la personnalité juridique et, vont donc s'éteindre toutes les situations qui résultaient de cette personnalité juridique (ex : fin au mariage, pacsés, fin au patrimoine).

B- Le statut et la protection du corps humain après le décès.

Le cadavre ne bénéficie plus des droits de la personnalité, comme le droit à la vie privée, ou le droit à l'image ; le cadavre est juridiquement considéré comme une chose, il n'est plus une

personne, mais c'est une chose protégée par rapport au lien que le cadavre a eu avec la personne. **L'article 16-1-1 du code civil**, rappelle que « ***le respect du au corps humain ne cesse pas avec la mort, les restes des personnes décédées, y compris les cendres, doivent être traitées avec respect, dignité et décence.*** ». Un arrêt de la Cour de cassation de la chambre civile du 16 septembre 2010 en est un exemple : dans cette décision, la Cour a considéré que le fait d'exposer des cadavres à des fins commerciales méconnaît les exigences de respect, dignité et décence qui sont vu à l'écart du cadavre. Cette décision concerné une exposition qui concerné Our Body (séance 1 TD). Également, une autre illustration réside dans **l'article 225-17 du code pénal** qui prévoit des ***sanctions en cas d'atteinte à l'intégrité du cadavre*** mais aussi en cas de profanation de tombeaux. Enfin, les volontés du défunt concernant ses funérailles doivent être respectées et toutes personnes qui méconnaîtrait sciemment les volontés du défunt peut faire l'objet de sanctions pénales.

Il y a des tempéraments à ce devoir de respects, des nuances ; en effet, le devoir de respect du cadavre n'empêche pas que le corps soit « utilisé » notamment pour des prélèvements d'organes. Le principe est que, lorsqu'une personne est décédée, il peut être procédé au prélèvement de ses organes dès lors qu'elle ne s'y est pas opposée de son vivant, c'est l'article l1232-1 alinéa 3 du code de la santé publique. Toutes personnes est présumée consentante au prélèvement de ses organes qui serait réalisé dans l'intérêt thérapeutiques d'autrui. Le principe d'une présomption, c'est qu'elle peut être renversée (sauf si elle est irréfragable). Cette présomption de consentement, peut être renversée, combattue, par la preuve d'un refus matérialisée par la personne, de son vivant, sachant que ce refus peut prendre la forme d'une inscription sur un registre nationale automatisé qui est prévu à cet effet. Le prélèvement d'organes ne peut avoir lieu que si un médecin a constaté la mort, c'est-à-dire la mort cérébrale : la destruction encéphalique irréversible.

Paragraphe 2 : Les évènements assimilés au décès.

Il y a des situations complexes dans lesquelles une personne disparaît, elle ne donne plus de nouvelles, sans pour autant qu'on retrouve son corps. On ne peut cependant pas dire qu'elle est décédée. IL y a deux procédures différentes : l'absence et la disparition.

A- L'absence

L'absence c'est l'état dans lequel se trouve un individu dont on ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. C'est par exemple le cas de celui qui dit qu'il va chercher du pain et ne revient jamais. Rien ne nous laisse penser qu'il est mort, on a simplement plus de nouvelle et il n'a pas laissé entendre qu'il ne reviendrait pas. C'est la personne qui ne paraît plus sans pour autant qu'on puisse penser qu'il est décédé. Cette absence est encadrée par le Droit, elle est définie à **l'article 112 du Code civil**, l'absence est caractérisée « ***lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelle.*** ». Pour être désigné absent juridiquement, il faut que la personne soit **absente physiquement**, qu'on ne **sache pas où elle se trouve** et, il ne faut **pas** avoir un **doute sérieux sur sa mort** (les circonstances ne doivent pas permettre d'envisager qu'elle est morte : c'est la différence avec la disparition). Une personne ne donne plus de nouvelle après avoir pris un avion et on sait

que l'avion s'est crashé : pas un cas d'absence. Les règles du code civil proposent des techniques de prises en compte des affaires de l'absent par le biais d'un régime qui est organisé en 2 étapes successives qui sont constatées par le juge.

1- La présomption d'absence

La présomption d'absence c'est une présomption de vie, c'est-à-dire que dans un premier temps, on suppose que l'absent est bien vivant même si on ne le sait pas où il est, c'est-à-dire qu'on suppose, on fait comme s'il allait revenir. Cette présomption d'absence est constatée par le juge qui peut être saisie par toutes personnes intéressées ou par le ministère public. Le but de cette présomption d'absence est évidemment de permettre de désigner un représentant de l'absent, qui aura pour mission de gérer son patrimoine, de le représenter, d'assurer la protection de ses biens et de ses affaires, comme s'il devait revenir. Pendant cette première période de présomption d'absence, le présumé absent est donc présumé toujours en vie et donc, d'un point de vue extrapatrimonial, son mariage n'est pas dissout par exemple. Pendant cette période il y a 2 possibilités : si le présumé absent revient, on a une preuve qu'il est en vie, il reprend possession de ses biens et on va mettre fin à toutes les mesures qui visées à le représenter ; s'il ne reparait pas pendant cette période, alors la 2^e phase, la 2^e période va pouvoir s'ouvrir : la déclaration d'absence.

2- La déclaration d'absence

Si l'absence se prolonge, alors le décès devient probable et donc, le tribunal va pouvoir prononcer un jugement de déclaration d'absence. Les conditions pour que le tribunal puisse déclarer l'absence, sont prévues par les **articles 122 et suivant du code civil** et, la loi impose un délai qui varie selon les cas. 1^e hypothèse : s'il y a bien eu constatations de la présomption d'absence par un juge, alors le tribunal peut déclarer l'absence lorsque 10 ans se sont écoulés depuis le jugement qui a constaté l'absence. A l'inverse, s'il n'y a pas eu constatation judiciaire de présomption d'absence, la déclaration d'absence est possible, elle pourra être prononcée seulement au bout de 20 ans à compter des dernières nouvelles. C'est une procédure organisée en 2 temps mais, il peut y avoir pendant la 1^e période aucune constatation, aucune saisie du juge.

Il faut savoir que la déclaration d'absence, à la différence de la présomption d'absence, c'est une présomption de décès. Les effets de cette déclaration d'absence sont énoncés aux **articles 128 et suivants du code civil** c'est-à-dire la déclaration d'absence est prononcée par le tribunal judiciaire et, elle produit sans rétroactivité tous les effets du décès. Si l'absent reparait, ou, que son existence est prouvée, après le jugement, **l'article 129 du code civil** précise qu'il est possible de demander l'annulation du jugement de déclaration d'absence. D'un point de vue patrimoniale, cela signifie que la personne va pouvoir redemander à récupérer ses biens : ses héritiers vont devoir lui restituer ce qu'il reste de son patrimoine ; mais au plan extra-patrimonial, le mariage ou le pacse qui avait été dissout en raison de la déclaration d'absence, restent dissous. Le fondement de cette règle est simple, si une personne est déclarée absente en 2010, elle redevient célibataire, cette personne peut refaire sa vie et se remarier ; si

l'absent revient : cela voudrait dire qu'elle est mariée à 2 personnes ; cela est impossible au lieu de la loi.

B- La disparition

Il y a des cas dans lesquels le régime de l'absence est inadaptée car, le décès de la personne est quasi certain, il est très probable. Dans ce cas, c'est le régime de la disparition qu'on va appliquer, qui est régi par les articles 88 à 92 du code civil. L'hypothèse de la disparition, c'est celle d'une personne qui a connu, vécu une situation périlleuse à la suite de laquelle elle ne donne plus signe de vie. Les exemples sont nombreux, par exemple : les passagers d'un vol qui s'est écrasé, des alpinistes qui se sont perdus en montagne après une avalanche, le soldat/militaire qui est parti en mission et ne revient pas etc. Dans ces exemples, il y a une forte présomption de décès qui pèse sur la personne disparue, bien que l'on n'ait pas trouvé un corps qui permet d'affirmer avec certitude que la personne est bien décédée. Pour toutes ces situations, le code civil organise une procédure de disparition qui permet d'établir une déclaration judiciaire de décès de la personne qui est disparue : c'est **l'article 88 alinéa 1 du code civil**. Selon cet article, le juge va judiciairement constater le décès lorsqu'une personne a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger alors même que le corps n'aurait pas été retrouvé. Ce jugement vaut acte de décès et, il va être publié sur les registres d'état civil. Les effets du jugement sont les mêmes que ceux d'un jugement déclaratif d'absence, c'est-à-dire que la personne est réputée décédée, sa succession est ouverte, son mariage est dissout etc. Là aussi, si le disparu revient (même si moins probable), il peut demander l'annulation du jugement, dans les mêmes conditions qu'en matière d'absence et les effets seront similaires ; c'est **l'article 92 du code civil** qui, pour les effets de la disparition renvoie aux articles **130 et suivants du code civil**.

Thème n°2 : L'identité des personnes physiques

Sous thème 1 : l'état des personnes

L'état des personnes se définit comme l'ensemble des éléments caractérisant la situation juridique d'une personne sur le plan individuel (date, lieu de naissance, nom, prénom, sexe, domicile...) et au plan familial (filiation, situation matrimoniale) mais aussi au plan politique (qualité de français ou d'étranger). Tous ces éléments qui caractérisent la personne, sont de nature à permettre d'individualiser la personne dans la société. En d'autres termes, on entend par « état des personnes » l'ensemble des caractéristiques de la personne qui déterminent selon la loi certains effets de droit et donc permettent de définir son statut juridique. L'état des personnes est traditionnellement vu comme un statut qui comprend des éléments imprescriptibles (on ne les perd pas dans le temps) et indisponibles (on ne peut les changer selon notre volonté). Attention, il y a des procédures qui permettent aujourd'hui des nuances. Cela signifie que, en principe, ni l'écoulement du temps, ni la volonté des individus ne peuvent suffire pour en modifier le contenu. Certains éléments de l'état des personnes peuvent en pratique connaître des modifications soit volontaires, soit par l'effet du temps.

- [Section 1 : les caractères de l'état des personnes](#)

L'état des personnes est indivisible, imprescriptible et indisponible.

[Paragraphe 1 : le caractère indivisible de l'état des personnes](#)

L'état est d'abord indivisible, c'est-à-dire qu'une personne ne peut avoir, simultanément 2 états différents et surtout, on ne peut pas réclamer certains attributs de son état et en répudier d'autres. C'est un tout indivisible ; par exemple, on ne peut pas, quand on est marié, réclamer un droit qui est réservé aux personnes divorcées.

[Paragraphe 2 : l'imprescriptibilité de l'état](#)

L'imprescriptibilité : caractère d'un droit ou d'une action en justice qui n'est pas soumis à la prescription, c'est-à-dire dont l'existence n'est pas modifiée par l'existence du temps.

L'imprescriptibilité de l'état signifie qu'en principe, ni la prescription extinctive ni la prescription acquisitive, ne touche l'état des personnes. Traditionnellement, on considère que l'état des personnes est imprescriptible mais on peut quand même nuancer ce principe.

Sur la **prescription extinctive**, cela signifie que, en principe, on ne perd pas son état de personne, pas d'éléments de son état, du seul fait de l'écoulement du temps, peu importe qu'on demeure plus de 30 ans sans user de son état. Par exemple, une personne mariée, ne redevient pas célibataire du seul fait qu'elle ne vit plus avec son conjoint depuis plus de 30 ans. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de réclamer un état, par exemple dans le domaine de la filiation, la prescription extinctive peut être opposée à la personne puisqu'en principe, passé un délai de 10 ans à compter de sa majorité, on ne peut plus exercer d'action liée à la filiation. On ne perd pas un élément mais, si on veut réclamer des éléments, il y a donc prescription (à 28 ans).

Le principe d'imprescriptibilité pour la **prescription acquisitive** signifie qu'en principe on ne peut pas acquérir un état par l'écoulement du temps. Cela étant, il y a des exceptions qui permettent de relativiser ce principe d'imprescriptibilité ; par exemple, la jurisprudence a déjà admis qu'une personne ait pu acquérir un nom de famille en raison d'une possession extrêmement prolongée.

[Paragraphe 3 : l'indisponibilité de l'état](#)

Lorsqu'on utilise l'expression « **indisponibilité** », en droit cela revient à un sens précis, lorsqu'on parle d'indisponibilité d'un bien ou d'un objet, cela signifie **qu'on ne peut pas disposer librement de cet objet, de ce bien**, autrement dit, on ne peut pas l'aliéner, c'est-à-dire le vendre, le donner, le léguer. On ne peut pas non plus le détruire ou en décider librement.

L'indisponibilité de l'état signifie que, l'état des personnes est hors d'atteinte des volontés individuelles. La seule volonté de l'individu ne peut permettre, en principe, de remettre en cause les éléments qui constitue son état. Le principe d'indisponibilité de l'état signifie que les individus ne peuvent librement agir sur des éléments de leur état mais, cela signifie aussi qu'il est interdit de porter atteinte aux éléments de l'état qui vise à identifier et à individualiser les personnes. L'interdiction de la **G**estation **P**our **A**utruï (GPA) est un exemple de ce principe d'indisponibilité de l'état des personnes. En effet, c'est notamment sur le fondement de l'indisponibilité de l'état des personnes que la Gestation pour Autruï est interdite en droit français. **La gestation pour autruï est aussi appelée maternité de substitution ; c'est un procédé médical qui consiste à faire porter un enfant** par une femme, qui est appelé **la mère porteuse**, qui va, à la naissance, **abandonner l'enfant au profit d'un couple** ou d'une personne seule, qu'on appelle les parents d'intention. En droit français, la gestation pour autruï est interdite, c'est une **interdiction** qui a d'abord été affirmé par la **Cour de cassation dans un arrêt rendu en Assemblée plénière le 31 mai 1991**, au nom de l'ordre public et de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes. À la suite de cette décision, le législateur est intervenu par l'une des **lois bioéthiques de 1994**, pour insérer dans le code civil un **article 16-7** qui dispose que « **toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autruï est nulle** » ; il est interdit, sur le territoire français d'avoir recours sur une mère porteuse. La gestation pour autruï porte atteinte à la fois au principe d'indisponibilité du corps humain de la femme, car elle constitue une mise à disposition du corps de la femme qui va accepter de porter un enfant pour l'abandonner. Également, elle porte atteinte à l'indisponibilité de l'état des personnes parce que, le procédé vise à désigner comme étant mère une femme qui n'a pas accouché de l'enfant. En droit français, le lien de filiation maternelle se constitue avec la femme qui accouche ; exceptés les cas de filiation adoptive.

Autour de la gestation pour autruï, les difficultés concernent les couples qui vont faire appel à une gestation pour autruï à l'étranger. Aujourd'hui, les difficultés résident dans le fait que la Gestation pour autruï est légale dans des pays très proche, et donc, il est courant que des Français se déplacent pour faire appel à une mère porteuse et qu'ils reviennent en France avec, soit un acte d'état civil étranger, soit un jugement d'état civil français qui les désignent comme les parents de l'enfant. Biologiquement, au moins un des deux parents d'intention est bien le parent biologique de l'enfant ; parfois les 2 parents sont bien les parents biologiques de l'enfant. La question s'est posée de savoir comment réagir juridiquement face à ces situations, il y a 2 points à aborder pour comprendre l'appréhension de la gestation pour autruï en droit français

1- *L'interdiction de la GPA en droit français n'empêche pas de transcrire le lien de filiation des enfants qui sont nés à la suite de la GPA à l'étranger.*

Il faut bien comprendre qu'on a une double difficulté face à ces situations :

- D'une part, la gestation pour autruï est fermement interdite en droit français

- En droit français, la mère juridique, celle qui sera juridiquement appelée mère est celle qui accouche. Cela vient d'un **adage** latin qui dit « **la mère est toujours certaine** ». L'acte étranger établit des liens de filiation qui sont donc faux.

On a eu une très longue évolution sur cette question ; **jusqu'en 2014**, la Cour de cassation, **refusait** au nom du principe de l'indisponibilité de l'état des personnes **de transcrire sur les registres français les actes d'état civil étrangers** lorsque les circonstances pouvaient laisser penser que **l'enfant était issu d'une convention de maternité de substitution. Une transcription c'est une copie d'un acte sur un registre officiel, pour assurer la publicité à l'égard des tiers** (ex : la transcription d'un acte de l'état civil). Si l'acte étranger est valide dans l'état étranger, on présume de sa validité et on le transcrit. Il y a eu beaucoup de décisions de justice et beaucoup d'arrêts qui affirmaient cette impossibilité de transcription, jusqu'à que le France soit condamnée, dans un **arrêt du 26 juin 2014 « Mennesson contre France », par la Cour Européenne des droits de l'Homme**. Dans cette décision, la Cour européenne a considéré que la position du droit français **portée atteinte au droit à l'identité des enfants** qui est une composante de la **vie privée qui est protégée par l'article 8 de la CEDH**. Selon la Cour, « **le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d'être humain, ce qui inclut sa filiation** ». La cour Européenne, dans cette décision a concentré toute son analyse sur la question de la filiation paternelle, c'est-à-dire qu'elle a considérée qu'il était contraire à l'intérêt de l'enfant de le priver d'un lien juridique dont la réalité biologique est avérée. La Cour européenne a dissocié la question de la filiation de maternité et de paternité, l'enfant est bien l'enfant d'un des deux parents. Depuis cette condamnation, la position de la Cour de cassation a évolué, dans un premier temps, la Cour de cassation a autorisé la **transcription de l'acte étranger lorsqu'il correspond à la réalité**, c'est-à-dire, lorsqu'il mentionne comme père, le **père biologique de l'enfant** (qui est la plupart du temps également le père d'intention) et **comme mère, la femme qui a accouché** (mère porteuse). C'est un **arrêt de la Cour de cassation qui a été rendu en Assemblée plénière le 3 juillet 2015, l'un des 2 numéro de pourvoi est le 15-50.002**. Cette position en 2015 était conforme au principe d'indisponibilité de l'état des personnes puisque, dans ces cas de figure, les documents étrangers ne désignaient pas comme mère juridique, la mère d'intention qui n'avait pas portée l'enfant. Le second parent devait donc établir son lien de filiation en demandant l'adoption de l'enfant afin d'être désigner parent juridiquement. Pour le **second parent d'intention**, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, la Cour de cassation lui permettait de faire **établir son lien de filiation en adoptant l'enfant**, cette idée est exposée dans l'**arrêt de la 1^e chambre civil de la Cour de cassation du 5 juillet 2017 numéro 16-16.455**.

Il y a eu ensuite encore une évolution, après que les époux Mennesson aient saisi la Cour de cassation pour obtenir le réexamen de leur affaire suite à la condamnation de la Cour Européenne et, ils refusaient que leur filiation soit établie différemment pour le père et pour la mère et, l'assemblée plénière de la **Cour de cassation, dans un arrêt du 4 octobre 2019** numéro 10-19.053 de pourvoi, est allée plus loin que ce qu'avait imposée la Cour européenne puisqu'elle est venue **autoriser la transcription intégrale des actes étrangers sur les registres français d'état civil pour les deux parents**. Elle n'a pas fait cette distinction entre la filiation maternelle et paternelle. Cette solution a été confirmée par plusieurs solutions ensuite par exemple dans un arrêt de la 1^e chambre civile dans un arrêt du 18 décembre 2019 (**VOIR**

AMETICE). On voit que dans cette décision, la Cour de cassation ne se réfère plus à la réalité des faits mais, elle se réfère à l'exactitude juridique au regard du droit étranger des éléments qui sont inscrits dans l'acte de naissance. Dans ces décisions on constate que, la Cour de cassation est venue **reconnaitre légalement la parenté d'intention sous réserve de régularité de l'acte établi à l'étranger** selon les formes usitées dans le pays où il a été dressé. La Cour de cassation change radicalement de posture et fait de la transcription intégrale le modèle de reconnaissance le moyen du lien de filiation alors même que, ni la Cour européenne, ni l'assemblée plénière précédemment l'avait imposée. Cette décision a été très critiquée mais a été réitérée plusieurs fois. Dans celle-ci, le deuxième parent n'avait pas besoin de passer par l'adoption. Cette évolution a été stoppée, elle a connu un **coup d'arrêt par la loi bioéthique du 2 août 2021** puisque, la loi bioéthique a complété **l'article 47 du code civil (A RECHERCHER)** pour préciser que la réalité des faits qui sont déclarés dans l'acte d'état civil étranger, qui établit ce mode de filiation, est apprécié au regard de la loi française. Concrètement, cette nouvelle rédaction implique que les faits déclarés par l'acte étranger doivent correspondre à la réalité des faits au sens qui est traditionnellement retenu par l'article 47 du code civil c'est-à-dire que l'acte doit mentionner l'accouchement par la mère porteuse, ce qui s'oppose à la transcription intégrale de l'acte de naissance d'un enfant né d'une gestation pour autrui, typiquement dans le cadre d'un couple composé de deux hommes. A la suite de la loi bioéthique, on **revient à la décision de 2015**, celui qui désigne comme mère la mère porteuse. Autrement dit, l'acte de naissance d'un enfant né d'une gestation pour autrui réalisée à l'étranger, ne peut désormais être transcrits sur les registres français que pour établir un lien de filiation à l'égard du parent biologique, ainsi que le permet la loi française.

(VOIR AMETICE EVOLUTION JURISPRUDENCE)

2- L'interdiction de la gestation pour autrui empêche toute action judiciaire visant à lui donner un effet lorsqu'elle a eu lieu sur le territoire français.

Quand la GPA a été conclu sur un notre territoire que le droit français, le droit s'est en partie adapté pour reconnaître dans une certaine mesure le lien de filiation de l'enfant. Toutefois, sur le territoire français, toute convention de gestation pour autrui reste strictement interdite et ne peut produire aucun effet. Un **arrêt de la 1^e chambre civile de la Cour de cassation du 12 septembre 2019 numéro 18-20.472 de pourvoi**, illustre cela. Dans cette affaire, un couple composé de deux hommes a conclu un contrat de gestation pour autrui avec une femme en France, l'un des deux individus a donné ses gamètes, on parle d'une insémination artisanale (pas effectuée par des médecins), la grossesse fonctionne, et ils conviennent ensemble de dire qu'à la naissance, la femme va l'abandonner et, l'un des deux hommes va reconnaître l'enfant. Cela est légalement correcte. Néanmoins, à la fin de la grossesse, la femme a dit au couple que l'enfant était décédé alors qu'elle l'a remis à un autre couple qui était en procédure d'adoption et qui s'était vu refusé l'agrément. L'époux du deuxième couple a reconnu l'enfant à la naissance et, a élevé cet enfant. Cependant, les parents d'intention, le premier couple en a eu connaissance et, le parent biologique a fait une action en justice pour contester le lien de filiation du père du second couple, ce qui est tout à fait légal hors GPA ; néanmoins, l'action a été jugée irrecevable car elle reposait sur un contrat prohibé par la loi.

- Section 2 : Les actes d'état civil

Paragraphe 1 : les différents actes et leur fonction

Il faut savoir que l'état civil est constitué de règles dites d'ordre public (de règles auxquelles on ne peut déroger) : **toutes personnes disposent d'un état civil, c'est une obligation légale**. L'acte d'état civil c'est un **acte authentique qui est celui qui a été reçu par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises**. Dans les actes d'état civil, **l'officier d'état civil constate les événements qui influent sur les états des personnes**. Plusieurs événements font l'objet de déclaration à l'état civil, et donc font l'objet de rédaction d'acte d'état civil, par exemple la naissance, le décès, le mariage ou encore la reconnaissance d'un enfant.

Quelle est la fonction des actes d'état civil ? Les actes d'état civil servent à attester l'existence juridique d'une personne mais aussi, à prouver son état ; par exemple son âge, sa filiation, son statut matrimonial etc. Les actes d'état civil ceux sont à la fois des éléments de publicité et des moyens de preuve.

Paragraphe 2 : le contentieux autour des actes d'état civil

Il arrive qu'un acte d'état civil comporte des erreurs ou des omissions c'est-à-dire des inexactitudes qu'il va falloir corriger. La rectification peut être administrative ou judiciaire.

A. Les rectifications administratives

La rectification sera administrative lorsque **l'erreur ou l'omission** sur l'acte est purement **matérielle**, c'est-à-dire dans les cas les **moins graves**, par exemple, la mauvaise orthographe d'un nom ou prénom, une erreur sur le domicile ou sur la profession, une erreur sur le sexe. La compétence pour procéder aux rectifications administratives est partagée entre le procureur et l'officier d'état civil qui détient l'acte.

1. La rectification par l'officier d'état civil

L'article 99-1 qui a été modifié en 2016 **permet à l'officier d'état civil** qui détient l'acte erroné de **corriger** directement certaines **erreurs ou omissions dont la liste est fixée à l'article 1047 du code de procédure civile** ; par exemple une erreur sur la date de naissance.

2. La rectification à l'initiative du ministère public

Le **procureur** est un magistrat d'un service qui relève du **ministère public**. **L'article 99-1 dernier alinéa du code civil** permet au **procureur de la république** de faire procéder à la **rectification administrative** des erreurs et omissions purement matérielles des actes d'état civil en donnant des instructions au dépositaire des registres. Le procureur a dans ses fonctions, une fonction d'administration du service d'état public. Il y a une circulaire qui explique la rectification des actes d'état civil, c'est la circulaire du **26 juillet 2017 : « de présentation de diverses dispositions en matière de droit des personnes et de la famille, de la loi n2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21^e siècle »**.

B. Les rectifications judiciaires

Quand l'acte contient des omissions ou des erreurs autres que purement matérielles, qui portent sur un élément substantiel de l'acte, **l'article 99 du code civil** prévoit une **procédure de rectification judiciaire**, qui est aussi réglementé par les articles 1048 et suivants du code de procédure civile. Dans cette hypothèse, c'est le président du tribunal judiciaire qui est compétent pour statuer.

Il va y avoir **rectifications judiciaires** dans **3** sortes de cas :

- il peut y avoir rectification pour **corriger** une **irrégularité initiale** dans la rédaction de l'acte ; c'est le cas lorsque l'acte est incomplet : l'officier d'état civil ne l'a pas signé ou a oublié le prénom ; ou, si l'acte est inexact : il y a eu une erreur sur le nom de la personne (pas orthographe mais mauvais nom)
- Il y a aussi rectification judiciaire pour mettre l'acte en harmonie avec des **faits nouveaux**, dans ce cas, l'inexactitude que l'on va rectifier ne s'est manifesté que postérieurement à la rédaction de l'acte. Par exemple, lorsqu'une personne a été autorisée à changer de nom ou à changer de sexe. A l'origine l'acte est tout à fait exact mais, postérieurement, l'acte est inexact avec des faits nouveaux. Ce n'est pas une irrégularité à l'origine
- C'est un ajout de la **loi bioéthique du 2 août 2021** qui est énoncé à **l'article 99 alinéa 2** : **« il peut y avoir une rectification judiciaire de la mention du sexe pour les personnes présentant une variation du développement génital à la naissance »**.

Il faut bien distinguer l'action en rectification d'état civil qu'on vient d'évoquer et, les rectifications d'état. Si demain, je veux changer mon sexe à l'état civil, je ne vais pas intenter une action de justification judiciaire : je vais d'abord saisir le juge sur le fondement des textes relatifs au changement de sexe pour qu'il m'autorise à changer de sexe (action d'état). C'est le jugement qui me permettra de faire suite à une action judiciaire d'état civil.

Sous-thème 2 : les éléments d'identification de la personne.

• Section 1 : le nom

Dans le dictionnaire juridique de **Gérard Cornu**, le nom est défini comme **« le mot ou ensemble de mot désignant une personne physique et se composant du nom de famille et du ou des prénoms avec parfois adjonction d'un pseudonyme, d'un surnom, d'une particule ou d'un titre de noblesse. »**. Le nom des personnes comporte obligatoirement 2 éléments, d'une part le nom de famille qui reflète, traduit, le rattachement juridique à une famille et, le ou les prénoms qui sont attribués à la personne au moment de la naissance.

Pour quelques éléments historiques, les principes onomastiques, c'est-à-dire les principes qui gouvernent la composition du nom, ont considérablement évolués au cours des siècles ; à l'époque Franque et au moyen-âge, les personnes ne portaient qu'un seul nom qui était choisi

par les parents. Très souvent, le nom choisi était celui du Saint sous la protection duquel on décidait de placer l'enfant. Progressivement, la coutume s'est développée d'ajouter à ce nom un surnom qui était souvent créée soit par rapport à une caractéristique physique, soit par rapport à un lieu ou par rapport à un métier (Louis le marin, Paul le Roux). L'enfant se voyait attribué en plus de son nom le surnom de son père ; c'est ce surnom qui est l'ancêtre du nom de famille.

Paragraphe 1 : l'attribution du nom

Aujourd'hui, on utilise l'expression de nom de famille depuis la loi du 4 mars 2002, alors que jusqu'ici on parlait de nom patronimique. L'expression non patronimique faisait référence au nom de famille du père, or aujourd'hui, elle a été supprimée car il y a un principe égalitaire, le nom d'une personne n'est pas forcément celui de son père.

Le nom de famille est une **institution de police civile** qui relève de l'intérêt général et, c'est la raison pour laquelle l'Etat exerce un contrôle important sur les questions relatives aux noms des individus. Néanmoins, le nom c'est **un élément de l'identité** des personnes qui relève de leur sphère privée et individuelle. On constate que le droit évolue pour prendre en compte les volontés individuelles dans l'attribution du nom de famille.

La question de l'attribution du nom de famille de la personne se pose à 2 événements : la naissance et le mariage.

A- L'attribution du nom à la naissance

Pendant longtemps, il était de tradition que l'enfant prenne le nom de son père et, c'est pourquoi on parlait de nom patronimique. C'est **la loi du 4 mars 2002** qui a rompu avec ce principe pour permettre aux parents de choisir le nom de famille de leurs enfants, soit le nom du père, soit le nom de la mère. Les règles de dévolution du nom de famille sont identiques quelque soit le statut matrimonial des parents. Les règles relatives à la dévolution du nom de l'enfant dépendent de l'établissement de sa filiation, c'est-à-dire le lien juridique qui unit l'enfant à son ou ses parents.

- *Si l'établissement du lien de filiation est simultané* : dans cette hypothèse, **l'article 311-21 du code civil** énonce le principe selon lequel lorsque la filiation d'un enfant est établie simultanément à l'égard de ses deux parents, c'est-à-dire en même temps, alors, les parents choisissent ensemble le nom de famille de l'enfant donc, les parents ont la possibilité soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés selon leur choix. En pratique, les parents doivent faire une déclaration conjointe de choix du nom qui est daté et signé par les deux, qu'ils vont transmettre à l'officier d'état civil quand ils vont déclarer la naissance. Cependant, à défaut de choix, si les parents ne transmettent pas de déclaration conjointe, l'enfant prend le nom de son père. Si les parents signalent à l'officier d'état civil leur désaccord concernant le choix du nom de l'enfant, alors l'officier d'état civil va mentionner les deux noms des parents, accolés selon l'ordre alphabétique. Le choix du nom de famille d'un enfant est important, il doit être réfléchi car, le choix sera le même pour tous les enfants que le couple pourra avoir ensuite. C'est le **principe d'unité du nom dans la fratrie**, fixé à **l'article 311-24** du code civil.

- Si l'établissement du lien de filiation n'est pas simultané à l'égard des deux parents : dans ce cas, lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent au moment de la déclaration de naissance (par exemple, une femme non mariée accouche et aucun homme ne reconnaît l'enfant), **l'article 311-23 du code civil** prévoit que l'enfant prend le nom de ce parent et, si ultérieurement le lien de filiation est établi à l'égard de l'autre parent, alors, les parents peuvent pendant la minorité de l'enfant, par déclaration conjointe devant l'officier d'état civil, choisir soit de lui substituer le nom du second parent, soit d'accoler leur deux noms dans l'ordre qu'ils choisissent, étant précisé que, si l'enfant a plus de 13 ans, son consentement est requis.

B- L'attribution de l'usage du nom par le mariage

En cas de mariage, chacun des époux conserve son nom de famille mais, acquiert aussi le **droit d'user du nom de son conjoint à titre d'usage**. Le mariage donne le droit de porter le nom de son conjoint. C'est une règle de **l'article 225-1 du code civil** qui précise que, « **chacun des époux peut porter à titre d'usage le nom de l'autre époux par substitution ou par adjonction à son propre nom, dans l'ordre qu'il choisit** ». La règle est égalitaire.

Ce droit n'est qu'une simple faculté, il n'y a **pas d'obligation** d'utiliser le nom de son conjoint et, il n'est pas nécessaire d'avoir l'accord de son conjoint pour porter son nom, du moins que le mariage est encore en cours. C'est un droit d'usage, cela ne modifie pas fondamentalement le nom de la personne.

En cas de **rupture du lien matrimonial**, le droit d'usage peut perdurer dans des conditions qui sont différentes selon la cause de la dissolution.

- Si le mariage prend fin en raison d'un des **décès** des époux, il est d'usage que le veuf/veuve, puisse **continuer à utiliser** le nom de son époux/épouse.

- En cas de **divorce**, en principe, chacun des époux **perd l'usage** du nom de son conjoint, **sauf si l'ex-époux/se l'autorise** à le conserver ou, si **le juge lui autorise**, à condition de justifier d'un intérêt particulier pour soi-même ou pour les enfants, c'est exposé à **l'article 264 du code civil**.

En cas de remariage, l'autorisation devient **caduque** sauf, à démontrer qu'on continue à avoir un intérêt à disposer du nom du précédent époux.

[Paragraphe 2 : les caractères du nom](#)

Les caractères du nom renvoient aux caractères de l'état des personnes : il est imprescriptible, indisponible mais aussi immuable. Le nom de famille est immuable, c'est-à-dire, qu'il ne peut, en principe être modifié et, cette immutabilité du nom de famille a pour conséquence que le nom est aussi imprescriptible et indisponible.

A- Le principe de l'immutabilité du nom de famille

L'origine de ce principe d'immutabilité, on la retrouve dans **l'article 1^{er} de la loi du 6 fructidor de l'an II** qui dispose que « **aucun citoyen ne pourra porter de nom, ni de prénom autre que**

ceux exprimés dans son acte de naissance, ceux qui les auraient quittés sont tenus de les reprendre ». Ce principe est très ancien, aujourd'hui il connaît des limites. Ce principe impose à chacun d'user de son nom dans la vie juridique à l'égard de l'Etat. Ce principe est pénalement sanctionné par deux infractions qui sont prévus aux **articles 433-19 et 434-23 du code pénal** qui concerne **l'usage d'un faux nom** et **l'usurpation du nom d'un tiers**. Ce principe de **l'immutabilité** du nom de famille implique en principe que le **nom de famille ne peut être modifié** mais, il faut évidemment nuancer parce qu'on constate aujourd'hui que le droit accorde de plus en plus d'importance à la volonté individuelle et, plusieurs circonstances permettent de changer de nom de famille. Ces circonstances sont des exceptions au principe d'immutabilité du nom de famille et, nous allons les évoquer.

1. L'EXCEPTION DU CHANGEMENT DE NOM RESULTANT A UN CHANGEMENT DE FILIATION

Une personne peut être **amener à changer** de nom de famille si, **sa filiation vient à être modifiée**. Par exemple, une personne qui fait l'objet d'une adoption aura la possibilité de prendre le nom de ses parents adoptifs. Sinon, une personne qui aurait le nom de son père et dont, le lien de filiation serait anéanti après une contestation en justice, l'enfant perd le nom de ce parent et prend le nom de son autre parent, cet exemple est l'hypothèse d'une personne qui est soit à l'origine ou subit une contestation de paternité, c'est-à-dire, selon un certain délai, il est possible de contester le lien de filiation ou le père juridique n'est pas le père biologique. Si ici, l'enfant est majeur, il doit consentir au changement de son nom, consécutif au changement de sa filiation, c'est **l'article 61-3 alinéa 2**.

2. LE CHANGEMENT EN PRESENCE D'UN INTERÊT LEGITIME

L'article 61 alinéa 1 précise que « **toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom** ». Malgré la formulation large de cet article 61 qui fait seulement référence à l'existence d'un intérêt légitime, **l'alinéa 2** donne par exemple l'hypothèse qui vise à **éviter l'extinction du nom** porté par un ascendant ou un collatéral jusqu'au 4^e degré et, il y a un exemple de cette hypothèse dans un **arrêt** de la **Cour Administrative d'Appel de Paris du 19 novembre 2020 n°19PA03840**. Il y a d'autres possibilités pour une personne à montrer qu'elle a des intérêts légitimes.

En pratique, l'intérêt légitime qui permet le changement de nom est admis dans plusieurs hypothèses, par exemple, quand le nom est ridicule ou grossier selon la personne qui le porte, pourrait arriver à prouver l'existence d'un intérêt légitime pour changer de nom. **Bernard Tessier** disait « **quand le nom suscite plus de sourire que respect** ».

Également, lorsqu'une personne possède un nom à consonnance étrangère, cette personne peut invoquer un intérêt légitime pour changer son nom (difficile à la prononciation etc.)

Le changement est un procédé administratif car la demande changement de nom est portée devant le garde des sceaux qui a la possibilité de demander l'avis du Conseil d'Etat. La demande doit s'accompagner d'un certain nombre de pièces justificatives. Si le changement de nom est accepté par le garde des Sceaux, il prend la forme d'un décret, publié sur le journal officiel. S'agissant du changement de nom d'une personne, **l'article 61-2 du Code civil** prévoit

que le changement s'étend de plein droit à ses enfants lorsqu'ils ont **moins de 13 ans et au-delà** de cet âge, leur **consentement** est exigé.

3. LE CHANGEMENT DE NOM A LA SUITE D'UNE NATURALISATION

Il est aussi possible de changer de nom de famille quand une personne acquiert la nationalité française, cela est prévu par la **loi du 25 octobre 1972**. Ainsi, toute personne qui acquiert la nationalité française peut demander la francisation de son nom et éventuellement de son ou ses prénoms lorsque leur apparence ou leur consonnance ou leur caractère étranger peut gêner l'intégration de la personne dans la communauté française. Cette demande de changement peut être formulée soit en même temps que la demande de la nationalité française, soit dans le délai d'une année qui suit son obtention. En pratique, le nom étranger va être traduit, si c'est possible, ou, on va légèrement modifier le nom pour lui donner une consonnance française.

4. L'ACQUISITION D'UN AUTRE NOM A L'ETRANGER

La loi dite **J21**, la **loi du 18 novembre 2016**, a ajouté des dispositions relatives au changement de nom lié à l'acquisition d'un autre nom à l'étranger. C'est l'**article 61-3-3 alinéa 1 du code civil** qui précise que « ***toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre d'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier d'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France, son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre état*** ». L'hypothèse qui illustre ce changement nom est le cas d'une personne qui serait binationale.

B- L'IMPRESCRIPTIBILITE DU NOM DE FAMILLE

Le principe d'immutabilité entraîne comme conséquence que le non-usage d'un nom, même prolongé pendant une longue durée n'est pas une cause d'extinction du droit pour son titulaire de le porter. En principe, en tant qu'élément de l'état de la personne, le nom est imprescriptible. Ce principe a été énoncé par la **Cour de Cassation** dans un **arrêt du 15 mars 1988** dans lequel la Cour a énoncé dans le numéro de pourvoi 85-17.162, l'**arrêt de Sainte Catherine** dit que « ***Si la possession loyale et prolongée d'un nom est propre à conférer l'individu qui le porte le droit à ce nom, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres qu'il n'a pas perdu en raison de l'usage d'un autre nom par ses ascendants les plus proches*** ». Dans cet arrêt, il s'agissait d'un individu qui portait comme nom de famille « Sainte Catherine », il invoquait que le nom porté par ses ancêtres c'était toujours écrit « de Sainte Catherine ». Il invoquait que, les services d'état civil avait commis une erreur lorsqu'il avait établi l'acte de naissance de son arrière-grand-père en 1840, sans la particule (de). L'extrait de l'arrêt de la Cour explique que, le fait d'avoir possédé, à la suite d'une erreur, pendant de nombreuses années le nom « Sainte Catherine », donnait le droit à cette personne d'avoir acquis ce nom. Néanmoins, cela n'est pas une obligation et, la personne peut choisir de renoncer à cette acquisition pour réclamer le nom de ses ancêtres qu'elle n'a pas perdu en raison du non-usage. **Imprescriptibilité** signifie que **l'écoulement du temps n'a pas d'effet** sur le nom. Cette solution concernant la possibilité d'acquérir un nom

du fait d'une possession prolongée, c'est une solution qui avait déjà été énoncée dans le passé par **la Cour de Cassation**, qui avait énoncé dans un **arrêt célèbre du 15 mai 1867** que, « ***la possession loyale et prolongée d'un nom permet à celui qui le porte de le conserver*** ».

Après l'arrêt « de Sainte Catherine », la jurisprudence a légèrement tempéré le principe d'imprescriptibilité et, dans 2 **arrêts**, du **25 mai 1992** et du **6 avril 1994**, la Cour de Cassation a tempéré le principe en indiquant que les **juges du fond** peuvent prendre en **considération** la **durée** respective et **l'ancienneté** des possessions invoquées ainsi que, les **circonstances** dans lesquelles elles se sont succédé.

La reconstitution du nom d'origine est possible mais, elle n'est pas accordée de Droit par les juges qui devront apprécier la situation selon les critères évoqués, à savoir la durée, l'ancienneté et circonstances. S'il s'avère que le nom des ancêtres, éventuellement altéré avec le temps, n'a jamais été revendiqué, les juges pourraient considérer que cela peut être analysé comme une volonté de la famille de renoncer à ce patronyme. Donc, **les juges ont un pouvoir d'appréciation**.

En définitive, on peut conclure que le principe traditionnel d'imprescriptibilité du nom de famille est aujourd'hui énormément nuancé ; ces décisions démontrent qu'un nom de famille peut s'acquérir ou se perdre du fait de l'écoulement du temps à certaines conditions.

C- L'INDISPONIBILITE DU DROIT AU NOM

Le droit au nom est, hors commerce juridique, il ne peut pas faire l'objet de convention. En principe, on ne peut pas vendre son nom de famille pour en tirer un profit, le nom échappe à la volonté individuelle. Néanmoins, ce principe de l'indisponibilité du nom peut être nuancé depuis l'**arrêt célèbre du 12 mars 1985** qui est l'**arrêt Bordas** dans lequel les juges ont considéré que, « ***le principe de l'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du nom patronimique qui empêche son titulaire d'en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou non commerciale*** ». Monsieur Bordas avait créé une maison d'édition, la société Bordas, lorsqu'il a quitté la société, il a demandé qu'elle cesse d'utiliser son nom de famille ; les juges ont refusé de faire droit à la demande car ils avaient considéré qu'il avait donné son nom à la société qui était devenu pour elle, un signe distinctif avec une notoriété et que la société devrait pouvoir l'utiliser.

• SECTION 2 : LE PRENOM

Le prénom c'est l'élément qui permet une différenciation individuelle de chaque membre de la famille qui porte le même nom. Toute personne doit obligatoirement avoir au moins 1 prénom.

PARAGRAPHE 1 : LE CHOIX DU PRENOM

Le ou les prénoms d'une personne sont choisis par les titulaires de l'autorité parentale, c'est-à-dire par les parents. Les textes ne précisent pas les cas de figures si les parents sont en désaccord sur le choix du prénom. On peut toutefois penser que dans cette hypothèse le juge aux affaires familiales pourrait être saisi pour trancher ce litige. Si les parents refusent de donner un prénom à l'enfant, c'est l'officier d'état civil qui choisira 3 prénoms pour l'enfant. De la même façon, c'est l'officier d'état civil qui attribue lui-même les prénoms quand il s'agit d'un enfant trouvé ou, d'un enfant dont il n'a pas l'identité des parents ; l'officier d'état civil va aussi donner 3 prénoms à l'enfant et, le dernier servira de nom de famille. La mère qui décide d'accéder sous X a quand même la possibilité de donner des instructions sur les prénoms qu'elle souhaiterait que l'enfant porte.

En principe, le choix du prénom par les parents est libre, cela n'a pas toujours été le cas ; pendant longtemps, les textes imposaient aux parents de choisir un prénom en usage dans les différents calendriers et, l'officier d'état civil ne pouvait pas inscrire d'autres prénoms que ceux relevant de cette sorte de liste. Cette limite à la liberté du choix du prénom a été supprimée par la **loi du 8 janvier 1993** qui a posé le **principe de liberté du choix du prénom**. Néanmoins, il faut savoir qu'une limite est énoncée à **l'article 57 alinéa 3 du Code Civil** « *lorsque les prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers, à voir protéger leur nom de famille* » l'officier d'état civil en informe sans délai le procureur de la République qui peut saisir le juge aux affaires familiales s'il estime l'objection fondée. Le juge aux affaires familiales (JAF), quand il est saisi, peut ordonner la suppression du prénom choisi sur les registres d'Etat Civil, s'il considère que ce prénom est contraire à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers. Si le prénom est rejeté, le JAF invite les parents à choisir un autre prénom et, à défaut pour les parents de faire un nouveau choix convenable de prénom, il lui attribuera lui-même ; c'est **l'article 57 alinéa 4. L'appréciation est souveraine par le juge en fonction de l'intérêt de l'enfant.**

Il y a 2 exemples de décisions sur ce thème :

- **Cour d'Appel de Rennes du 25 janvier 2016**, numéro 15/01705 : il s'agissait d'un enfant dont les parents lui avaient donné le prénom « **Léo-Pard** », les juges ont considéré que ce prénom était contraire à l'intérêt de l'enfant car il fait référence à un animal et, le prénom pourrait lui entraîner des moqueries de la part de son entourage, autres enfants. Les parents n'ayant pas proposé un autre prénom, le juge lui a donné le prénom de « **Léo** ».
- **Cour de Cassation du 15 février 2012** numéro 10-27.712 : les parents avaient appelé leur enfant « **Titeuf** », le héros de la bande dessinée et, les juges ont considéré qu'il fallait supprimer le prénom.

En sens inverse, certains prénoms peuvent sembler curieux, étranges mais sont acceptés et autorisés sur les registres d'état. C'est le cas de la jeune fille « **Megan Renault** » et, selon les juges, le prénom Megan, est « normal » et le modèle pourra disparaître. Également, le prénom « **Mickey** » est admis, le prénom « **Zébulon** » ou encore « **Térébenthine** ». Lorsqu'on prend en compte ces différentes jurisprudences, cela montre que le juge a bien une appréciation.

PARAGRAPHE 2 : LA MODIFICATION DU PRENOM

Le prénom étant lui aussi immuable, son changement n'est qu'exceptionnellement admis.

A- LE CHANGEMENT DE PRENOM EN PRESENCE D'UN INTERÊT LEGITIME

L'article 60 du code civil précise que « ***toute personne peut demander à l'officier d'état civil à changer de prénom*** », cet article a été modifié par la loi J21 du 18 novembre 2016, c'est-à-dire que, jusqu'à cette loi, la demande de changement de prénom devait être déposée au juge aux affaires familiales et, il fallait démontrer un intérêt légitime pour changer de prénom. Les intérêts légitimes qui peuvent être reconnus sont nombreux, cela peut être religieux, familial, par rapport à un prénom ridicule etc. Depuis la loi de 2016, la demande de changement de prénom est directement faite à l'officier d'état civil et, l'article 60 du code civil n'affirme plus directement qu'il faille démontrer un intérêt légitime. Néanmoins, cet article maintient un certain contrôle au moins indirect car il est précisé que, si l'officier d'état civil juge que la demande de changement de prénom ne revêt par un intérêt légitime, il peut saisir le procureur de la République qui aura la possibilité de s'opposer au changement de prénom. Dans ce cas, s'il y a eu opposition du procureur, le demandeur devra saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il statue.

B- LES 2 AUTRES MOTIFS DU CHANGEMENT DE PRENOM (francisation ou adoption)

Lorsqu'un enfant est adopté, le tribunal peut, sur demande du ou des adoptants, modifier les prénoms de l'enfant, cela est souligné aux article 367 pour l'adoption plénière et 361 pour l'adoption simple.

Lorsqu'une personne acquiert la nationalité française, elle peut demander la francisation de son prénom sur le même fondement que la francisation du nom, c'est-à-dire pour favoriser son intégration dans la communauté française. Celle-ci sera effectuée soit en changeant ce prénom soit en ajoutant un autre prénom avec une consonnance française.

- SECTIONN 3 : LE SEXE

Le sexe constitue un élément de l'état des personnes spécifié dans l'acte de naissance et autour du sexe il y a 2 points.

PARAGRAPHE 1 : LE SEXE DANS SA DIMENSION SOCIALE

Traditionnellement, le droit civil déduisait plusieurs conséquences de l'appartenance à l'un ou l'autre sexe mais, c'est évidemment de moins en moins vrai en raison du principe de l'égalité des sexes qui prend de plus en plus d'importance et qui s'est de plus en plus matérialisé dans nos règles juridiques. Par exemple :

- l'impossibilité, jusqu'en 2013, de se marier avec une personne du sexe identique. On ne pouvait se marier qu'avec une personne de sexe opposé.

- jusqu'à la loi bioéthique du 2 août 2021, la procréation médicalement assistée n'était ouverte qu'aux couples de sexes différents. Aujourd'hui pour les couples de 2 femmes ou aux femmes célibataires, la PMA est aussi ouverte. La gestation pour autrui continue de constituer une Contestation d'ordre publique.

Dans la **dimension sociale** du sexe, le principe d'égalité du sexe a une valeur Constitutionnelle, au 3ème alinéa du préambule de 1946. Les femmes et les hommes disposent des mêmes droits politiques. Dans la **sphère privée et familiale**, ce principe d'égalité des sexes s'est traduit par le principe d'égalité entre époux. Autrefois le père était chef de famille. Ce principe d'égalité des sexes dans la famille a transformé la puissance paternelle en autorité parentale. Dans les **rapports sociaux**, l'identité sexuelle est prise en compte pour affirmer le principe d'égalité des sexes. En revanche, l'orientation sexuelle est totalement ignorée par le droit c'est-à-dire que le droit est indifférent à l'orientation sexuelle des personnes sauf pour sanctionner les discriminations qui seraient faites entre les personnes à raison de leurs orientations sexuelles ou de leurs identités de genre. La discrimination étant punie car elle est considérée comme une atteinte à la dignité de la personne.

PARAGRAPHE 2 : LE SEXE EN TANT QU'ÉLÉMENT D'IDENTIFICATION DE LA PERSONNE

L'identité sexuelle traduit l'appartenance d'une personne à la gent féminine ou masculine. Du point de vue de l'état civil, toute personne est soit un homme, soit une femme.

A- L'OBLIGATION D'INSCRIRE UN SEXE À L'ÉTAT CIVIL

À la naissance, les médecins vont déterminer l'identité sexuelle de la personne qui est déterminée sur la base de l'apparence. Il y a des situations pour lesquelles l'apparence du sexe n'est pas si évidente et des enfants peuvent naître de sexe indéterminé. Il y a deux possibilités : soit parce que l'apparence sexuelle ne correspond aux caryotypes, soit parce que l'enfant présente des caractères des deux sexes. En doctrine, on peut les devenir comme des personnes « hermaphrodite », « inter genre » ou « intersexuelle ».

Dans ces hypothèses, le droit ne voit pas la possibilité de mentionner à l'état civil un sexe neutre, cette position résulte d'une décision d'un **arrêt de la Cour de cassation, Grande Chambre civile du 4 mai 2017**. On devra donc écrire soit sexe féminin soit sexe masculin, on est dans une binarité du genre, sexuelle. Il y a une souplesse, jusqu'à aujourd'hui, une **circulaire du 28 octobre 2011, n°16-17.189**. On s'était penchée sur ces questions et en présence d'enfant né de sexe indéterminé, cette circulaire préconise d'inscrire le sexe qui apparaissait comme le plus probable par rapport aux traitements qui semblaient envisageables. La circulaire prévoyait qu'en cas d'impossibilité de se prononcer, de trancher entre les deux sexes, laisser la possibilité de reporter l'inscription de la mention du sexe pendant un délai d'un ou deux ans, délai qui servirait à déterminer définitivement le sexe à la suite de traitement approprié, et on conseillait au parent de choisir un prénom mixte. Cette exigence de binarité de nos actes d'état civil a conduit à des pratiques médicales qui sont très critiquables, sur des enfants très jeunes (- de 18 mois) dont le but était une véritable assignation sexuelle. Ces pratiques ont été très critiquées et portent atteinte à l'intégrité

physique de ces enfants, qui ne sont pas en mesure d'effectuer un choix. On a des reculs de personnes ayant subis ces traitements et qui, une fois adulte, souffrent d'un point de vue physique et d'un point de vue moral. De nombreux rapports ont été rendus sur cette décision, rendu par rapport aux revendications qu'on put faire ces personnes nées de sexe indéterminé qui réclament une reconnaissance juridique. Une évolution par la **loi du 2 août 2021** qui est venue inscrire dans la loi des dispositions relatives aux personnes intersexe, et un nouveau chapitre a été inséré dans le Code de la Santé Publique qui est dédié aux enfants présentant une variation du développement génital. Ce chapitre prévoit un protocole spécifique avec une prise en charge médicale pluridisciplinaire dans des établissements hospitaliers, désignés centres de références. C'est établissement se trouvent à Lyon, Lille, Paris et Montpellier. La prise en charge est énoncée à l'Article L2131-6 du Code de la Santé Publique, et concrètement la loi n'interdit pas les opérations sur des nouveaux nés, simplement le dernier alinéa de cet article précise qu'en principe, le consentement de l'enfant doit être recherché s'il apte à participer à la décision. Cela signifie que les interventions chirurgicale ou médicales qui auraient pour but de conformer l'apparence esthétique des organes aux représentations binaires homme/femme, ces interventions restent possibles avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale. C'est une première évolution. La restriction à ces interventions n'est pas directement écrite dans les articles, mais comme ces opérations chirurgicales entraînent généralement des mutilations, les médecins, en principe, ne devraient pouvoir y recourir que si l'opération relève d'un motif médical très sérieux, c'est l'Article R4127-41 du Code de la Santé Publique ; c'est une disposition qui n'est pas propre aux enfants nés de sexe indéterminé.

La **loi bioéthique du 2 août 2021** a aussi modifié l'Article 57 du Code Civil, pour prévoir, comme le faisait la **circulaire de 2011**, la possibilité de n'inscrire aucun sexe à l'état civil, mais seulement pendant les 3 premiers mois de vie, avec l'autorisation du procureur. Ce délai de 3 mois, n'a pas pour objectif premier de mettre en œuvre des traitements médicaux. Ce raccourcissement du délai s'explique par le fait que la loi bioéthique a aussi modifié l'Article 99 du Code Civil pour permettre une rectification judiciaire de la mention du sexe sur l'acte de naissance, au profit des personnes pour lesquelles il est médicalement constaté que leur sexe ne correspond pas à leur véritable sexe. C'est le premier sur la question de l'identification du sexe d'une personne, notre état civil est fait en fonction d'une binarité homme/femme, pour les personnes de sexe indéterminé, il faudra inscrire un sexe, avec modification ultérieure possible.

B- LA POSSIBILITÉ DE CHANGER DE SEXE À L'ÉTAT CIVIL

Il arrive qu'une personne ressente son identité de genre différemment que celle exprimée par son corps, son génotype, son caryotype et son phénotype. Autrefois, cette situation était décrite comme le « syndrome de benjamin » ou « syndrome transsexuelle » en faisant référence au médecin qui avait identifié ces questions. Aujourd'hui on étend plus couramment

l'expression « dysphorie de genre ». La problématique juridique est de savoir comment le droit a pris en compte ces situations, sachant que la question principale à laquelle il a fallu répondre juridiquement a été de savoir si on peut changer la mention du sexe à l'état civil (et la mention du prénom aussi). Le droit français été évolutif sur ces questions. La réponse du droit français a également été évolutive.

1. LE DROIT FRANÇAIS, D'ABORD HOSTILE AU CHANGEMENT DE SEXE À L'ÉTAT CIVIL :

Au tout début, à la fin du XXe siècle, la jurisprudence française a d'abord refusé toute reconnaissance juridique à l'égard des personnes qui auraient changé de sexe d'un point de vue médical. Initialement, la réponse des juges français, en refusant toute reconnaissance juridique, c'était un **arrêt du 16 décembre 1975**, concernant un individu qui avait subi une opération chirurgicale à l'étranger et avait obtenu la modification des attributs de son sexe médicalement et la Cour a répondu : « *le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, au respect duquel l'ordre public est intéressé, interdit de prendre en considération les transformations corporelles ainsi obtenues.* ». Plusieurs décisions postérieures ont confirmé cette décision par la suite. Ce refus du droit français, de changer la mention du sexe à l'état civil, a été condamné par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, dans une décision du **25 mars 1992, c'est l'arrêt « Bottela contre France »**. Selon la Cour européenne, la position des juges français portait atteinte au droit au respect de la vie privée protégé par l'Article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droit de l'Homme et des libertés fondamentales. À la suite de cette condamnation, la jurisprudence française a évolué, dans un **arrêt rendu en Assemblée plénière par la Cour de cassation le 11 décembre 1992**, la Cour a admis qu'une personne transsexuelle puisse voir son état civil modifié concernant la mention de son sexe à l'état civil et qu'elle puisse changer de prénom. L'arrêt a été rendu sur le fondement de l'Article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droit de l'Homme et des libertés fondamentales. La Cour a admis dès 1992 le changement de sexe, mais elle imposait certaines conditions strictes puisqu'elle imposé au requérant de démontrer :

- la réalité du syndrome transsexuel (on ordonnait des expertises judiciaires pour le vérifier),
- un traitement médicaux chirurgicale subit dans un but thérapeutique (il fallait démontrer qu'il y avait eu une transformation physique définitive et irréversible),
- une apparence physique proche de l'autre sexe,
- un comportement social correspondant au sexe psychologique.

Ces 4 conditions ont été rappelées dans des décisions qui ont suivies, notamment **deux décisions du 7 juin 2012, n°10-26.947 (première chambre civile) et n° 11-22.490**. Ces 4 conditions et surtout les 2 premières ont été appréciées de façon un peu différente en fonction des juges du fond, ils pouvaient faire preuve de plus ou moins de souplesse. La condition liée à la preuve de l'irréversibilité de la transformation de l'apparence (la 2ème) a

été condamnée par la Cour Européenne de Droits de l'Homme, dans un **arrêt du 6 avril 2017**, c'est l'**arrêt « garçon et Nicot »**. Dans cette décision, la Cour européenne a considéré que la deuxième condition énoncée était attentatoire au droit au respect de la vie privée. La Cour Européenne a, en effet, considéré, au paragraphe 135 de l'arrêt, que *« le rejet de la demande (de changement de sexe), au motif qu'il n'avait établi le caractère irréversible de la transformation de leur apparence, c'est-à-dire, démontrer avoir subi une opération stérilisante ou un traitement médical entraînant une très forte probabilité de stérilité, s'analyse en un manquement, par l'état défendeur (la France), à son obligation positive de garantir le droit de ces derniers au respect de leurs vies privées. »* (Elle analyse prioritairement les deux premières conditions mais a condamné surtout pour la deuxième). Cette condamnation s'appuyait sur les anciennes conditions posées par la jurisprudence française pour le changement de sexe.

2. LA POSITION ACTUELLE DU DROIT FRANÇAIS

C'est la **loi dite J21, du 18 novembre 2016**, qui a modifié la procédure pour obtenir une rectification des actes d'état civil, s'agissant de la mention du sexe à l'état civil. En effet, l'Article 61-5 du Code Civil dispose désormais que *« toute personne majeure ou mineure émancipée, qui démontre par une réunion suffisante de faits, que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil, ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue, peut en obtenir la modification. »* Il faut donc désormais, pour obtenir le changement de sexe (pas des conditions cumulative) :

- que le demandeur se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiquer,
- que le demandeur soit connu sous le sexe revendiqué par son entourage familial, amical ou professionnel,
- que le demandeur ait obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.

L'Article 61-6 alinéa 3, précise bien qu'il n'est pas obligatoire de démontrer que la personne a subi des traitements médicaux. On le voit également à travers l'Article 61-5, le droit nouveau, depuis 2016, ne comporte plus que les conditions qui étaient autrefois exigées par la jurisprudence pour obtenir la modification du sexe à l'état civil. Désormais le changement de sexe à l'état civil doit être accordé si la personne démontre qu'elle possède l'état de l'autre sexe. Aucune condition liée à une conversion sexuelle n'est imposée. Il n'y a pas de précisions concernant les personnes mineures (non émancipés vu l'Article 61-5), dans les textes.

-> **Possession d'état** : Désigne l'apparence d'un état donné servant, notamment, de preuve du mariage, de la filiation, ou de la nationalité. Elle se compose de 3 éléments :

- *Nomen* : la personne porte le nom correspondant à l'état dont elle a la possession,

- *Tractatus* : la personne est traitée par son entourage (sa famille) comme ayant l'état en cause,
- *Fama* : la personne a la réputation aux yeux du public, d'avoir l'état dont apparence est donnée.

La demande de changement de sexe doit être présentée devant le tribunal judiciaire. Quand le changement de sexe est accordé, l'acte de naissance de la personne est modifié. Mais si la personne est mariée ou a des enfants, la mention de son changement de sexe n'est pas transcrite sur l'acte de naissance des enfants ou sur l'acte de mariage de la personne. Le changement de sexe à l'état civil n'a pas d'effet sur le lien de filiation qui aurait pu être établi auparavant entre la personne et ses enfants, c'est-à-dire que si un homme a eu un enfant en 2010 et obtient le changement de son sexe en 2016, il reste père à l'état civil en 2016, sans modification. L'assouplissement des conditions pour obtenir la rectification du sexe à l'état civil, aboutit aujourd'hui à de nouvelles questions en matière de filiation, d'où **l'arrêt de la Cour de cassation, Première chambre civile, du 16 septembre 2020, n° 18-50.080 et n°19-11.251**. Un homme marié a obtenu son changement de sexe à l'état civil, il avait déjà des enfants, et devient femme ; mais, conformément au droit nouveau, il ne change pas physiquement de sexe (n'a pas subi d'intervention chirurgicale). Il reste donc marié et a un nouvel enfant, on a donc un couple de femme qui va donner naissance à un enfant. L'enfant né officiellement de deux personnes mentionnées comme femmes à l'état civil, la question qui s'est posée a été de savoir quel lien de filiation à établir pour la mère transgenre. Évidemment, la personne transgenre voulait établir un lien de filiation maternelle pour que ce soit conforme à son identité à l'état civil. Les juges du fond ont rejeté sa demande, dans un premier temps, et ils ont considéré qu'on devait l'inscrire comme étant parent biologique de l'enfant. La Cour de cassation a cassé cette décision et elle a énoncé que « *une personne transgenre, homme devenu femme, qui après la modification de la mention de son sexe dans les actes de l'état civil, procrée avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles, n'est pas privé du droit de faire reconnaître un lien de filiation biologique avec l'enfant, mais ne peut le faire qu'en ayant recours au mode d'établissement de la filiation réservé au père.* ». Elle est donc femme à l'état civil mais devra établir un lien de paternité à l'état civil.

(-> le ministère public a le droit de former un pourvoi en juridiction, lorsqu'il lui semble juste, même s'il n'est pas directement concerné par le litige.)

La conséquence de cette décision est que l'on va demander à une personne étant une femme à l'état civil, de procéder à une reconnaissance de paternité de l'enfant, et donc d'être désigné père de l'enfant. Cela pourrait changer car la **loi du 2 Aout 2021** a ouvert la procréation médicalement assistée à un couple de deux femmes, donc une règle de double filiation.

- **SECTION 4 : LE DOMICILE**

Parmi les éléments d'identification d'une personne on retrouve le domicile, étant le lien de rattachement géographique et territorial.

PARAGRAPHE 1 : LA DETERMINATION DU DOMICILE

A- LES PRINCIPES RELATIFS AU DOMICILE

L'Article 102 du Code Civil dispose que le domicile de tout français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Cet article illustre la fonction générale du domicile, c'est un élément d'individualisation de la personne physique qui a pour but de la rattacher, pour l'exercice de ses droits civils, à un point du territoire. La doctrine classique (écrits des auteurs) a déduit deux principes de l'Article 102 du Code Civil :

- le premier étant un principe de nécessité du domicile selon lequel toute personne doit avoir un domicile, c'est un élément de police qui est indispensable car la loi attache des conséquences à la détermination du domicile. Ce principe de nécessité du domicile explique par exemple que les personnes qui n'ont pas de domicile fixe ou de résidence fixe, ont la possibilité d'élire domicile auprès d'un centre communal ou intercommunal d'actions sociales, ou auprès d'un organisme agréé à cet effet. C'est l'Article L264-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles.

- le deuxième est le principe d'unicité du domicile, c'est-à-dire que toute personne n'a qu'un seul domicile, même si elle a plusieurs résidences.

B- LES MODALITÉS DE DETERMINATION DU DOMICILE

Il y a des cas dans lesquels la loi détermine directement le domicile de certaines personnes. C'est le cas par exemple pour les mineurs non émancipés pour lesquels l'Article 108-2 du Code Civil précise que leur domicile se situe chez leurs pères et mères. De même pour les majeurs en tutelle, leur domicile est fixé chez leur tuteur, c'est l'Article 108-3. En dehors de ces cas de déterminations légales du domicile d'une personne, le domicile est soumis à la règle du libre choix, c'est-à-dire que tout majeur est en principe libre de choisir son domicile. Le libre choix du domicile est un attribut du droit au respect de la vie privée et les juges sont souverains pour déterminer le domicile d'une personne qui est une question de fait.

Deux éléments sont pris en compte pour déterminer le domicile :

- un élément matériel, c'est-à-dire que le domicile est le lieu du principal établissement de la personne,
- un élément psychologique, volontaire, c'est-à-dire que le domicile se situe là où la personne a eu l'intention de fixer son établissement.

PARAGRAPHE 2 : LES EFFETS ATTACHÉS A CETTE DETERMINATION

Il y a de multiples intérêts autour de la détermination du domicile, c'est-à-dire que le domicile joue plusieurs fonctions en droit. Il faut citer la fonction procédurale, jouée par le domicile puisque le domicile est attributif de compétences territoriales des tribunaux. En effet, selon l'Article 42 alinéa 2 du Code de Procédure Civile : « *S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.* », et l'Article 43 du Code de Procédure Civile dispose que « *Le lieu où demeure le défendeur s'entend : s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.* ».

Le domicile permet aussi de déterminer le lieu de célébration ou d'accomplissement de certains actes juridiques. L'Article 165 du Code Civil concerne le mariage qui doit être célébré par la commune où l'un des deux époux à son domicile. La loi donne toutefois une place importante à la résidence de la personne, la résidence étant une notion qui rend compte d'une situation de faits, c'est le lieu où une personne réside, mais celui-ci ne coïncide pas toujours avec son domicile. Il y a donc une certaine notion de permanence pour le domicile.

THEME 3 : LA PROTECTION DE L'INTEGRITE PHYSIQUE DES PERSONNES

Le principe de dignité est important à connaître pour ce thème. C'est un principe qui ressort à l'article 16 du Code civil. C'est un principe fondamental du droit des personnes qui implique que, les intérêts de l'Homme doivent primer sur tous les autres intérêts comme les intérêts de la science. On ne peut pas instrumentaliser les personnes, mais aussi, qu'on doit faire obstacle à tout ce qui pourrait dégrader la personne humaine, à la fois dans son intégrité physique que morale. Le principe de dignité fait obstacle à tout ce qui pourrait conduire à traiter la personne comme une chose. C'est un principe qui a une valeur constitutionnelle et, avant qu'il soit inscrit dans le code civil, ce principe de dignité était déjà présent de nombreux textes internationaux comme le Préambule de la charte des nations unies, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ou, la Convention dite d'Oviedo qui date de 1997. Le principe de dignité pourrait être qualifié comme un principe matriciel dans le sens où tous les autres principes qui sont applicables au corps, en découle de ce principe de dignité ; ils viennent l'appliquer, le concrétiser, le traduire, le matérialiser. La dignité est le fondement

des principes que nous allons voir et, c'est aussi le fondement des droits qui protègent l'intégrité morale des personnes que nous étudierons dans le thème 4.

PARAGRAPHE 1 : LA PROTECTION DE LA VIE HUMAINE

A. LE DROIT A LA VIE

Le droit à la vie est affirmé dans les textes de droits internes mais aussi dans les textes internationaux de protection des droits de l'Homme. Le Droit interne (de la nation) s'oppose au Droit international. En Droit interne, on en trouve une illustration à **l'article 66-1 de la Constitution** qui pose un principe **d'interdiction de la peine de mort**. Le droit à la vie est particulièrement protégé en droit pénal, dans le code pénal, puisque le code pénal sanctionne, **réprime, le fait de donner la mort à autrui, c'est l'article 221-1 du code pénal**. Le droit à la vie est aussi protégé à travers **l'article 16 du code civil** qui affirme que « la loi garantit le respect de tout être humain ... ».

En droit international, on peut citer de nombreux textes qui protègent le droit à la vie. On peut citer **l'article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme** qui affirme que « ***tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne*** ». **L'article 6-1 du Pacte des Nations Unies** relatif au droit civil et politique de 1966 qui affirme que « ***le droit à la vie est inerrant à la personne humaine, ce droit doit être protégé par la loi*** ». De plus, il y a l'article 2 paragraphe 1 de la Charte de l'Union Européenne et, c'est aussi **l'article 2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales** sur laquelle la Cour a rendu d'importantes décisions.

Le droit à la vie est affirmé, protégé dans tous ces textes mais, il y a des tempéraments, des limites.

- On peut citer tous les exemples d'atteintes qu'on peut porter à l'embryon et au fœtus, par exemple, **l'interruption volontaire de grossesse**.
- On peut citer la **légitime défense** que l'on retrouve en droit pénal à **l'article 122-5 du Code pénal**

B. EST-CE QU'IL EXISTE UN DROIT A LA MORT ?

On peut se poser la question de l'euthanasie. **L'euthanasie** peut être définie comme un acte qui vise à provoquer la mort d'une personne souffrant d'une maladie incurable, dont le but est d'abrégé ses souffrances, son agonie. L'euthanasie fait partie des débats qui sont sans cesse questionnés.

Le droit français a fait le choix d'accompagner le mieux possible la fin de vie mais, de ne pas permettre l'euthanasie active, c'est-à-dire le fait de mettre fin délibérément à la vie. Il n'y a donc pas de droit à la mort. En revanche, on a essayé depuis les années 2000, d'accompagner au mieux la fin de vie, de la soulager. C'est pourquoi, les différentes lois qui ont pu être adoptées sur la question de la fin de vie, ont mis en place des dispositifs pour prendre en

compte la souffrance des personnes en fin de vie, l'objectif étant de respecter leur dignité. Néanmoins, le **Droit français ne permet pas aux équipes médicales, aux médecins, de provoquer délibérément la mort : l'euthanasie active.**

- La première étape est la **loi du 4 mars 2002** qui a insérée dans le code de la Santé publique, un **article l1110-5** qui prévoit que les médecins doivent mettre en **œuvre tous les moyens disponibles pour assurer à chacun, une vie digne jusqu'à la mort**, au besoin, en ayant recours à des **soins palliatifs**, décrits à **l'article l1110-10 du code de la santé publique**. On affirme donc un droit à mourir avec dignité, d'assurer une fin de vie digne à chacun avec des soins palliatifs.

- **La loi du 22 avril 2005** : la **loi dite Leonetti** qui est venu consacrer un droit à mourir dans la dignité par **l'arrêt des soins et par la mise en place de soins palliatifs**. Depuis cette loi, les personnes qui souffrent d'une maladie incurable, pour lesquelles on n'a pas de perspective de guérison, ont le droit de demander l'arrêt des soins en vertu du **principe d'autodétermination de la personne** et donc, les **personnels médicaux ont le droit de laisser mourir** et, il est même imposé, **d'éviter l'obstination déraisonnable** dans les **soins**, ce qu'on appelle aussi **l'acharnement thérapeutique**.

- **La loi du 2 février 2016** : c'est une continuité de la loi de 2005, c'est un prolongement mais, la loi de 2016, renforce encore plus la place de la volonté des malades dans la prise en charges de la fin de vie et, l'innovation majeure c'est la consécration d'un **droit à la sédation profonde et continue**, qui est énoncé aujourd'hui à **l'article l1110-5-2 du code de la santé publique** dans les cas suivants lorsque « **le patient est atteint d'une affection grave et incurable et dont son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable** ». Toute personne qui remplit les conditions posées dans cet article, peut demander à être placé en sédation profonde et continue **jusqu'à son décès**. Concrètement, la sédation profonde et continue est le fait de placer la personne dans un **coma artificiel**, de l'endormir jusqu'à qu'elle meurt de façon « naturelle », sans que l'acte médical mette fin à la vie. Une grande partie de l'opinion publique est favorable à cette loi, néanmoins, d'autres pensent que c'est une hypocrisie de la justice française car, les soins palliatifs réduisent le temps de vie.

Si le patient ne peut pas exprimer sa volonté et que le médecin considère que le maintien des traitements relève de l'obstination déraisonnable et qu'il arrête le maintien en vie, il doit procéder à une sédation profonde et continue.

Les questions liées à la vie font objet de réflexions permanentes pour les améliorer. Le mois de janvier 2021 a notamment été marqué par le dépôt d'une nouvelle proposition de loi à l'Assemblée nationale visant à affirmer le libre choix de la fin de vie et, à assurer un accès universel aux soins palliatifs en France.

L'affaire **Vincent Lambert** est importante sur ce sujet. C'est un homme qui est devenu tétraplégique avec un accident de moto en **2008** et, après cet accident, il était dans un état végétatif et, les seuls soins qu'on lui administrait consistaient en une alimentation et hydratation artificielles. Il y avait un conflit au sein de la famille car son épouse était favorable à un arrêt des soins alors que ses parents souhaitaient continuer les traitements. La question que les

médecins se sont posés était de savoir si on n'était pas face à un cas d'obstination déraisonnable et le médecin était favorable à l'arrêt des soins. Ils ont donc pris, à plusieurs reprises, la décision d'arrêter les soins, la mise en place a toujours été suspendue car la famille contestait ces décisions. Entre la première décision d'arrêt des soins, prononcée par les médecins et, l'arrêt effectif de ces soins, il s'est écoulé presque 10 années. Finalement, **l'arrêt des traitements date du 28 juin 2019** et, Vincent Lambert s'est éteint le 11 juillet 2019.

Il n'existe pas un droit à la mort mais un droit à mourir dans la dignité, un droit aux soins palliatifs, un droit à l'arrêt des soins. On est, pour le moment, toujours dans une **législation du « laisser mourir »** et pas du « faire mourir ».

PARAGRAPHE 2 : LA PROTECTION DU CORPS HUMAIN

La **protection du corps humain** résulte des **lois bioéthiques du 29 juillet 1994**, qui ont dotées le corps humain d'un statut et, qui ont inscrit au sein du code civil, plusieurs principes relatifs au corps humain, que l'on retrouve énoncés à **l'article 16-1 du code civil** :

- **Alinéa 1** : « **chacun a droit au respect de son corps** », c'est le principe de **respect**
- **Alinéa 2** : « **le corps humain est inviolable** », principe d'**inviolabilité** du corps humain
- **Alinéa 3** : « **le corps humain, ses éléments et ses produits, ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial** » c'est le principe de **non-patrimonialité** du corps humain.

A- L'INVOLABILITE DU CORPS HUMAIN

L'inviolabilité du corps humain signifie que **le corps ne peut faire l'objet d'aucune atteinte**, en principe ni par la personne elle-même, ni par des tiers. Ce principe vise surtout à encadrer les éventuelles atteintes qui pourraient être portées au corps d'une personne par un tiers. Cette protection est énoncée plus spécifiquement, est traduite à **l'article 16-3 du Code civil** qui pose un principe de **respect de l'intégrité du corps humain** « **il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir** ». A travers cet article, on s'aperçoit que le corps humain est protégé mais, il y a des conditions. Pour qu'une atteinte puisse être portée au corps humain d'une personne, il faut que 2 conditions soient réunies.

1. LES CONDITIONS POUR POUVOIR PORTER UNE ATTEINTE AU CORPS HUMAIN

a. UNE FINALITE SPECIFIQUE

D'abord, l'atteinte portée au corps humain doit correspondre, pour être possible, à l'une des finalités énoncées à l'article 16-3 à savoir, la nécessité médicale pour la personne ou, l'intérêt thérapeutique d'autrui. A ces 2 finalités, le Code de la santé publique en ajoute une troisième qui est la finalité de la **recherche scientifique**, à **l'article l1121-2 du Code de la santé publique**.

- **la nécessité médicale pour la personne** : il faut noter que, les actes médicaux sont des actes qui portent atteinte au corps humain. C'est pourquoi, pour être effectués, le Code civil impose qu'ils répondent à une nécessité médicale. Ce cadre posé par le principe d'indivisibilité, impose donc que les médecins ne peuvent en principe réaliser des actes médicaux qui ne sont pas commandés par une nécessité médicale. Cette nécessité médicale est appréciée largement puisqu'elle englobe autant des actes indispensables à la santé de la personne que, des actes simplement utiles pour la personne, comme des actes de préventions, de diagnostics etc. C'est aussi parce que la nécessité médicale est interprétée de façon extensive que, la chirurgie purement esthétique est autorisée, que l'on va considérer comme répondant à une nécessité médicale, par rapport au bien-être, au réconfort qu'elles peuvent apporter à la personne.

- **l'intérêt thérapeutique d'autrui** : une atteinte peut être réalisée sur le corps d'une personne lorsqu'il répond à une finalité liée à l'intérêt thérapeutique d'autrui. C'est cette seconde finalité qui permet, par exemple, de procéder à des prélèvements d'organes, pour les transplanter sur une autre personne. Si l'on n'avait pas prévu cette deuxième condition, on ne pourrait pas, vivant, donner un organe. Pour les prélèvements et les dons d'organes qui concernent une personne vivante, il faut, bien sûr avoir le consentement du donneur mais, il faut en outre prouver **un intérêt thérapeutique direct pour le receveur, c'est l'article l1231-1 du code de la Santé publique**. Le **don d'organe du vivant** d'une personne, est considéré comme un acte de solidarité qui doit en principe **intervenir entre proches**. Cela répond aussi à l'objectif de non-patrimonialité car, on veut éviter une marchandisation. L'idée est donc de dire que le don d'organe doit se réaliser pour des proches, **l'article 1231-1 du Code de la santé publique** précise que **le donneur doit en priorité être le père ou la mère du receveur ou, éventuellement des membres de la famille plus élargie** comme le conjoint, le frère, la sœur, les enfants, les grands parents, oncles, tantes etc. Cette liste est une gradation, depuis **2011**, le cercle a été élargi à **toutes personnes prouvant un lien affectif d'au moins 2 années avec le receveur**, c'est l'article l1231-1 de la santé publique. En cas d'incompatibilité de don d'organe entre proche, la loi autorise aussi les dons d'organes croisés entre les personnes vivantes qui ne se connaissent pas mais qui présentent entre elles une forte compatibilité, c'est l'article l1231-1 alinéa 3.

b. LE CONSENTEMENT DE LA PERSONNE CONCERNEE

En principe, le corps humain étant inviolable, toute personne doit donner son consentement avant tout acte médical, avant toutes interventions sinon, cela constitue une atteinte à son intégrité physique et ce, même si l'acte en question répond à une des deux finalités évoquées en (a). C'est **l'alinéa 2 de l'article 1231-1**. L'exigence de consentement de la personne vise à protéger cette personne contre les tiers. Le consentement à l'acte doit être éclairée, le patient doit au préalable recevoir une information éclairée, loyale, claire et appropriée pour que son consentement soit donc éclairé. Il y a des tempéraments à l'exigence de consentement, quand la personne n'est pas à même de consentir, ce qui sera le cas par exemple pour une personne inconsciente, pour laquelle on va pouvoir présumer son consentement par rapport à la nécessité de l'intervention ou du traitement. Cette condition de consentement signifie aussi

que toute personne est libre de refuser des soins, c'est l'**article 1111-4 du Code de la santé publique** et, le médecin qui respecte cette décision ne sera pas poursuivi pour n'être pas intervenu. Au contraire, si le médecin intervient malgré le refus de la personne, il pourrait voir sa responsabilité engagée. Il y a eu plusieurs décisions autour de la question des transfusions sanguines pour les personnes qui sont témoins de Jéhovah. C'est très complexe pour les médecins car, ils doivent obéir au refus mais dans certains cas, pour sauver leur vie ils ont tout de même réalisé l'acte et sont passés outre du refus (dit non éclairé). Dans ces décisions, lorsqu'on considère que leur opération à sauver la vie, les médecins ne sont pas poursuivis.

2. LES TEMPERAMENTS AU PRINCIPE D'INVIOIABILITE

Plusieurs tempéraments peuvent être cités au principe d'invioiabilité du corps humain.

- La première nuance est l'**ordre public** : on peut évoquer les campagnes de vaccination obligatoire, dans cette hypothèse, le consentement est contraint. Ces campagnes sont, certes, des formes d'atteinte à l'intégrité physique de la personne mais, elles sont mises en œuvre dans un objectif de santé publique qui est un objectif d'intérêt général et qu'on considère qu'il doit primer sur l'intégrité physique individuelle de chacun.

- La **protection d'autres libertés fondamentales** : il faut bien comprendre que le principe de protection du corps humain devrait en principe protéger le corps, également contre la volonté personne elle-même. Pour autant, le droit au respect de la vie privée et, l'autonomie individuelle peuvent parfois prendre le dessus et, il existe un **droit à l'autodétermination** et ce pouvoir d'autodétermination vient tempérer le principe d'indisponibilité du corps humain que nous avons déjà évoqué. Cela se matérialise par le fait qu'on peut se faire tatouer, percer etc. Le droit à l'autodétermination est aussi appelé le droit à l'autonomie personnelle par la Cour Européenne des Droits de l'Homme et, c'est un droit qui est défendu très largement par la Cour Européenne. On peut citer une décision qui illustre cette protection de la liberté individuelle ; c'est un **arrêt du 17 février 2005 « KA et AD contre Belgique »** qui concernait 2 personnes belges, un médecin et un magistrat, qui avaient été condamnés pénalement en Belgique pour des pratiques sadomasochistes. Ils invoquaient leurs droits à faire ce qu'ils veulent avec leur corps et, dans cette décision la Cour a évoqué que *« le droit pénal ne peut en principe, intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties qui relèvent du libre arbitre des individus et [...] il faut des raisons particulièrement graves pour que soit justifiée une ingérence des pouvoirs publics dans le domaine de la sexualité »*. Le consentement des personnes peut suffire, selon la Cour à justifier des atteintes qui sont portées au corps. Dans cette affaire, la Cour a considéré que les autorités belges avaient pu légitimement intervenir car, tout le débat a été autour du consentement de l'une des personnes, à savoir l'une des épouses, dont les faits laisser douter qu'elle était consentante aux actes et aux pratiques auxquelles elle était soumise. Il y a donc le **droit à la vie privée**. Il y a également la **liberté religieuse**. On peut ici évoquer la question de certaines pratiques religieuses comme la circoncision. On constate qu'il y a aussi une tolérance qui est fondée sur la liberté de religion sur le principe du libre exercice des cultes. C'est pour cela que ce n'est pas attentatoire aux principes du respect du corps humain. Il y a une confrontation entre le droit à l'invioiabilité du corps humain et droit à l'exercice d'un culte, ici, la religion l'emporte.

B. LA NON-PATRIMONIALITE DU CORPS HUMAIN

1. LE PRINCIPE DE NON-PATRIMONIALITE DU CORPS HUMAIN A ETE INSCRIT DANS LE CODE CIVIL PAR L'UNE DES LOIS BIOETHIQUE DE 1994.

C'est un principe d'ordre public qui figure à l'article 16-1 alinéa 3 et qui est précisé dans les **articles 16-5 et 16-6**. Ces deux articles démontrent une volonté de protéger la personne contre les tentations de réification du corps humain, c'est-à-dire des tentations viseraient à traiter le corps humain comme une chose. Ces articles interdisent que soit constitué sur le corps un droit susceptibles d'être échangé, d'être monnayé, de faire l'objet d'une contrepartie patrimoniale. En réalité, à part les conventions de gestations pour autrui, les conventions à titre gratuit son licites pour permettre des interventions jugées utiles dans l'intérêt général comme les dons d'organes ou les dons de gamètes mais, on évite de faire entrer le corps humain dans le champ économique en interdisant, en principe, toute commercialisation des éléments du corps humain.

2. QUELLES SONT LES COROLAIRES DE CE PRINCIPE

Le principe de non-patrimonialité explique par exemple l'anonymat et la gratuité qui commande tout don d'un élément du corps humain. **L'anonymat** est un principe essentiel rappelé à **l'article 16-8 du code civil**. La gratuité : on ne peut pas monnayer des éléments du corps humains, en principe.

3. LES EXCEPTIONS

Le principe de non-patrimonialité est affirmé avec force mais, n'empêche pas que certains produits du corps humain peuvent faire l'objet de convention onéreuse. Cette possibilité résulte de la combinaison de 2 articles : **l1211-8 du Code de la Santé Publique et, r1211-49 du Code de la Santé publique** qui listent les **produits qui peuvent être vendus** : le lait maternel, les cheveux, les poils, les ongles.

Également, les textes prévoient une indemnité compensatrice pour les personnes qui se prêtent à des **recherches biomédicales**, c'est **l'article l1121-11 du code de la santé publique**.

THEME 4 : LA PROTECTION DE L'INTEGRITE MORALE DES PERSONNES

La question de l'intégrité morale des personnes s'oppose à la question d'intégrité physique. La protection de l'intégrité morale c'est la protection de toutes les **qualités incorporelles, immatérielles de la personne** qui la définissent dans **sa relation aux autres**. C'est la protection de l'esprit, de la personne, de sa voix, de son image, de sa vie privée, de son honneur, de son ressentis. Tous ces éléments désincarnés sont protégés par l'affirmation de droits subjectifs que nous allons développer dans ce thème. Nous verrons également au cours de ce thème que, la protection de l'intégrité morale des personnes est très souvent mise en balance avec d'autres droits et libertés fondamentales comme la liberté d'expression ou encore la liberté de la presse. Le **principe de dignité** est également mobilisé s'agissant de l'intégrité moral des

personnes et, il semble connaître des évolutions particulières ces dernières années en jurisprudence.

- SECTION 1 : LES DROITS SUBJECTIFS PROTECTEURS DE L'INTEGRITE MORALE DES PERSONNES

PARAGRAPHE 1 : LE DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET DROIT A L'IMAGE

Le droit au respect de la vie privée et à l'image est protégé simultanément par l'article 9 du code civil, par **l'article 8 paragraphe 1 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'UE**. C'est donc un droit fondamental, il est constitutionnellement protégé depuis la **décision du Conseil Constitutionnel du 23 juillet 1999**. L'article 9 du code civil relatif au droit au respect de la vie privée, a été introduit en droit français par la **loi du 17 juillet 1970**.

Avant cette loi, notre droit civil ne comprenait pas de texte protégeant de manière générale la vie privée des individus. Du fait de cette absence de fondement, de texte, c'est la jurisprudence qui avait édifiée un régime protecteur de la vie privée, un **régime prétorien**, c'est-à-dire jurisprudentiel, qui reposait sur les règles de la responsabilité civile de droit commun, l'ancien article 1382, c'est-à-dire **l'article 1240 du code civil**. Cet article 1240 actuel impose, pour engager la responsabilité civile d'une personne, que 3 conditions soient réunies :

- Démontrer une **faute**
- Démontrer un **préjudice subit**
- Démontrer un **lien de causalité** entre la faute et le préjudice

En 1970, on a consacré cet **article 9 dans le code civil** dont la consécration permet un allègement de la charge de la preuve à apporter car, désormais, la personne victime d'une atteinte à la vie privée peut obtenir réparation en **prouvant seulement l'atteinte, le comportement d'une autre personne qui lui a porté atteinte à sa vie privée**. Il n'y a **pas de nécessité de prouver un préjudice**. L'article 9 institue un véritable droit subjectif dont la violation appelle automatiquement une réparation.

A. LES CONTOURS DE LA VIE PRIVEE PROTEGEE ET LES TITULAIRES DU DROIT

Le droit au respect de la vie privée est une notion générale que les textes ne définissent pas. C'est le **juge**, au gré des affaires, qui a **contribué à définir les contours** de ce qu'est la vie privée et donc de ce qui est protégé au titre de la vie privée. Le droit au respect de la vie privée c'est le droit de garder secret un certain nombre d'information relevant de la sphère privée de chacun. La notion est complexe, il n'y a pas de liste dans les textes mais c'est l'étude de la jurisprudence. **Relèvent de la vie privée, les événements qui se déroulent des lieux privés et, relèvent aussi des informations privées indépendamment du lieu où elles se déroulent.**

1. LA VIE PRIVEE AU SENS STRICTE : STRICTO SENSU

Font évidemment partie de la vie privée, toutes les informations **relatives à la vie personnelle d'un individu, relatives à la vie familiale, sur la vie sentimentale, conjugale ou extraconjugale, relatives à la filiation, les loisirs, l'état de santé, le domicile**. Les **opinions** d'ordres intellectuelles sont aussi protégées ou encore, la **pratique d'un culte**. Un arrêt de la 1^e chambre Civile du 9 septembre 2020, numéro de pourvoi 19-16.415 : il s'agissait d'un reportage télévisé dans l'émission « faites entrer l'accusé », qui était consacré à une affaire d'abus sexuel. Dans cette affaire, l'audience pénale avait été menée à huit-clos et, le coupable avait été condamné à 20 ans. Les journalistes donnaient l'identité de la victime dans le reportage et, beaucoup d'information au sujet des circonstances précises dans lesquelles la victime avait subi ces abus. La victime a donc invoqué une atteinte à sa liberté privée selon l'article 9, qui a été reconnu. Dans cet arrêt, il y a aussi des poursuites sur la loi de la presse, notamment la divulgation de l'identité de la victime.

2. LE DROIT A L'IMAGE

Le droit à l'image est un droit qui a été dégagé par la jurisprudence, il n'est pas expressément consacré par la loi. C'est un **droit qui permet à toutes personnes d'interdire au tiers la prise, la reproduction et la publication de son image** et ce, par quelques moyens que ce soit, c'est-à-dire, photographie, vidéos, dessins, images numériques, images de synthèse etc. C'est la reconnaissance d'un **droit de contrôle sur la reproduction et la divulgation de son image**. **Toute violation du droit à l'image** est sanctionnée sur le fondement de **l'article 9 du code civil** qui concerne donc la vie privée et, le droit au respect de la vie privée et le droit à l'image, sont soumis au même régime juridique, c'est-à-dire, même titulaire et même sanction. Néanmoins, il ne faut pas les confondre et, avoir à l'esprit que ceux sont 2 droits différents, ne protègent pas la même chose. Le droit à l'image ne fait pas double emploi avec le droit au respect de la vie privée. En effet, bien souvent, la photo qui pouvait être prise d'une personne sans son consentement constituera une atteinte à la fois à son droit à l'image mais aussi à son droit au respect de la vie privée. Par exemple, si une photo est prise d'une actrice au bord de sa piscine, chez elle, il y a à la fois une atteinte au droit à l'image car c'est une photo d'elle sans son consentement mais aussi, une atteinte à la vie privée car on voit chez elle, peut être ses enfants, sa maison, son corps etc. Il pourra aussi y avoir, selon la photo qui est prise, une atteinte au droit à l'image, sans que cette atteinte ne constitue une atteinte à la vie privée. Par exemple, si on prend la photo d'un coureur cycliste pendant une course et qu'on l'utilise pour une publicité pour les vélos, on a une atteinte au droit à l'image car photo prise et diffusé sans consentement mais, pas une atteinte à la vie privée car c'est une course publique etc.

Ceux sont **deux éléments et droit qui sont distincts pour l'article 9** : c'est le **droit au respect de la vie privée mais aussi le droit à l'image**.

Une décision de la **Cour de cassation de la 1^e chambre civile du 2 juin 2012** : un acteur américain reprochait à un éditeur d'avoir publié des photos de lui, sur une plage, au cours d'un moment privé. Le magazine était le magazine « Lui ». Cet acteur a agi en justice à la fois contre la maison d'édition du magazine mais également contre l'agence de presse photographique qui avait pris la photo et fournie à l'éditeur. Il demande l'interdiction de la commercialisation

de ce cliché. Curieusement, les juges du fond avaient rejeté ses demandes en retenant qu'en l'absence de toute preuve de commercialisation du cliché par l'organe de presse à l'éditeur, il n'était donc pas démontré que, l'organe de presse avait commis une faute. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel et, elle rappelle que **la seule constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation**.

3. LES AUTRES COMPOSANTES DE LA VIE PRIVEE

Comme autres composantes de la vie privée, on peut citer le **domicile** qui est considéré comme le **siège de l'intimité des personnes**. Toutes les informations comme l'adresse, le numéro de téléphone d'une personne sont considérés comme des informations privées qui ne peuvent être délivrées sans le consentement de l'individu. Le domicile étant rattaché à la vie privée, il fait l'objet d'une protection plus particulière : chacun peut refuser l'accès à son domicile et, le droit pénal **sanctionne la violation de domicile comme étant une atteinte à la vie privée** sur le fondement de l'**article 226-4 du code pénal**. Evidemment, il y a des exceptions comme les perquisitions qui sont autorisées par un juge judiciaire qui est protecteur de la vie privée. Le domicile c'est le lieu privé par excellence. Le domicile protégé s'entend plus largement que le domicile tel que nous l'avons défini à l'article 102. En effet, le **domicile protégé c'est n'importe quel lieu où la personne peut se dire chez elle**. Cette définition englobe aussi des hébergements temporaires, comme une chambre d'hôtel, une chambre d'hôpital, une tente, un mobil home, une caravane etc. Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 avril 2005, n°04-85.637 dans laquelle on constate que le véhicule d'une personne est considéré comme un lieu privé.

Les **correspondances** c'est-à-dire, les lettres, les emails, les conversations électroniques, font aussi partie de la vie privée et donc sont aussi protégés sur le fondement de l'article 9 du code civil alors même que l'article 9 n'y fait pas référence expressément. Les articles 8 de la CEDH et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'UE y font correspondance, à la différence de l'article 9 du code civil. **L'article 8 de la CEDH précise « toute personne à le droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de ses correspondances ».**

La jurisprudence, en matière d'atteinte à la vie privée, est difficilement lisible car les **juges** se livrent à une **appréciation casuistique**, c'est-à-dire, une approche au cas par cas dans les litiges qui leurs sont soumis. Dans certaines décisions, on constate parfois que la communication ou la **divulgaration de faits qui relève de la vie privée** d'une personne, n'est **pas forcément constitutive** d'une atteinte à la vie privée, quand l'information est considérée comme **anodine**. La 2^e chambre civile du 8 juillet 2004, n°02-17.458 : un article avait été consacré au sujet du futur mariage d'une célèbre journaliste. Il y avait donc des détails qui étaient donnés sur sa vie privée : comment elle avait rencontré son époux, quels étaient leurs projets etc. Elle a agi pour une atteinte à la vie privée et, la Cour de cassation relève que ces commentaires étaient anodins et donc ne caractérisaient pas une atteinte au respect de la vie privée. Il y a donc une certaine part de subjectivité. C'est également un contentieux dans lequel le **pouvoir d'appréciation des juges du fond est très important**.

4. LES TITULAIRES DU DROIT

L'article 9 du code civil dispose que : « **chacun a droit au respect de sa vie privée** ». Ce droit au respect de la vie privée appartient à tout individu quel que soit son âge, sa fortune, ses fonctions, sa notoriété. La décision de la Cour de cassation du 27 février 2007, n°06-10.393 a énoncé que toute personne a droit au respect de sa vie privée.

A partir de cette affirmation, il y a **2 éléments** qu'il faut avoir à l'esprit :

- Tout individu a le droit à sa vie privée, même les personnes connues, publiques, avec de la notoriété, célébrités, ont le droit à la vie privée. La seule difficulté va être de délimiter ce qui va être de leur vie publique est qui n'est donc pas protégé, par rapport à ce qui relève de leur vie privée. Forcément, les personnes publiques intéressent la presse, que ce soit la presse à scandales ou la presse qui délivre des informations au public. Pour ces **personnes publiques**, il faut ménager un équilibre entre leur **droit au respect de la vie privée** et, d'un autre côté, la **liberté de la presse** et le **droit du public à l'information**.
- Pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie privée (englobant le droit à l'image), il faut remplir **2 conditions** :
 - La personne **victime doit être vivante**, cela signifie que, le droit d'agir pour le respect de la vie privée s'éteint avec le décès de la personne, les droits de la **personnalité sont intransmissibles : ils disparaissent avec leur titulaire**. Concrètement, on peut révéler des éléments de la vie privée d'une personne décédée et personne ne peut agir pour l'atteinte de la vie privée de la personne décédée. Cela est la même chose pour le droit à l'image.
 - Il faut **pouvoir identifier la personne** : soit sur l'image. La Cour de cassation du 5 avril 2012 n°11-15.328

B. LES COMPORTEMENTS REPRIMES ET LES MODALITES DE LA PROTECTION

1. QUELS SONT LES COMPORTEMENTS CONSIDERES COMME ATENTATOIRES A LA VIE PRIVEE

Il existe **3 formes** principales d'atteinte à la vie privée :

- La **recherche d'information intime** sur une personne : c'est le fait d'espionner une personne, d'écouter une conversation derrière une porte, de cacher un micro dans les affaires d'une personne. Le simple fait de chercher c'est une atteinte, même si les informations ne sont pas divulguées.
- La **divulgaration d'information privée sur une personne**. Soit elle est la suite de la première atteinte, soit qui peut en être indépendante. Une personne peut divulguer des informations privées qui viennent directement de la personne en question, sans l'avoir espionner.

- La **reproduction illicite de l'image de la personne** : c'est une atteinte au droit à l'image, il y a des nuances, quand une personne se trouve dans un lieu public, il est possible de reproduire et de diffuser une image prise dans un lieu public, par exemple lors d'une manifestation, si cette image n'est pas directement cadrée sur la personne et, si sa diffusion est justifiée par l'information du public. Il ne faut pas non plus détourner l'image de son contexte par exemple, récupérer une photo d'une personne prise dans un bar et, s'en servir pour faire une campagne de prévention contre l'alcool.

2. COMMENT SONT SANCTIONNEES LES ATTEINTES A LA VIE PRIVEE

Il y a des outils de **réparations en nature** et des **sanctions pécuniaires** qui peuvent être ordonnées. **L'article 9 alinéa 2 du code civil autorise le juge à empêcher ou à faire cesser une atteinte à la vie privée**, par exemple en ordonnant la saisie de publications qui n'ont pas encore été vendues, ou il peut ordonner qu'on coupe certains passages d'un film ou d'un livre. Le juge, dans ce cas, la plupart du temps est **saisi en référé**, une **procédure rapide**. Ces mesures sont exceptionnelles et donc effectuées de fonction stricte car cela reste une forme de censure donc une atteinte à la liberté d'expression.

Toute atteinte illicite au droit au respect de la vie privée ouvre droit à réparation et ouvre droit à des sanctions civile et pénale : au pénal **l'atteinte à la vie privée** constitue un **délit**, c'est **l'article 226-1 du code pénal** « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. 3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci.

*Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale. Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende », d'un point de vue civil, la personne qui est victime peut **demandeur une réparation** même si elle n'a pas subi de préjudice en raison de l'atteinte. Cette réparation peut prendre **2 formes** : une réparation par **l'allocation de dommages et intérêts** dont le montant est déterminé par le juge, et la réparation en nature vue précédemment.*

PARAGRAPHE 2 : L'HONNEUR, LA PROTECTION DE LA PERSONNE CONTRE LA DIFFAMATION ET L'INJURE

Le droit à l'honneur d'une personne est protégé par 2 types d'infractions qui sont la diffamation et l'injure, définies à **l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse**. La **diffamation** est définie comme « **toute allégation ou imputation d'un fait qui porte**

atteinte à l'honneur ou la considération de la personne à qui le fait en question est imputée ». L'injure c'est « **une expression outrageante ou méprisante mais, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis ».**

Il y a dans la diffamation, **l'exception de vérité**, si l'information s'avère vraie avec une preuve. L'expression de vérité peut faire valoir que si le fait ne concerne pas la vie privée.

Ces deux comportements sont considérés comme des **délits** lorsque les propos sont **prononcés publiquement**, c'est-à-dire lorsqu'ils sont communiqués via un des **modes de communication cités à l'article 23 de la loi de la presse** : des écrits, des affiches etc. **Sinon**, ceux sont de **simples contraventions**.

La difficulté est de la **différencier de la critique**, elle **protégée** par la **liberté d'expression**.

PARAGRAPHE 3 : LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

La **présomption d'innocence** est le principe en vertu duquel chacun doit être présumé **innocent** tant que sa **culpabilité n'a pas été établie**. On le trouve dans **l'article 9 de la DDHC**, dans **l'article 6 paragraphe 2 de la Convention Européenne des droits de l'Homme**, et, depuis **1993** elle est inscrite à **l'article 9-1 du code civil** selon lequel « **chacun a le droit au respect de la présomption d'innocence** ». Ce droit à la présomption d'innocence implique qu'il est interdit de présenter une personne comme étant coupable (pénalement) tant qu'elle n'a pas été condamnée. La présomption d'innocence est surtout importante pour les organes de presse, notamment lorsque les journalistes présentent un fait divers et qui, de façon hâtive, déclarent qu'une personne est condamnée alors que l'enquête est encore en cours. En réalité, il n'y aura d'atteinte à la présomption d'innocence que, si l'auteur s'exprime de façon catégorique et non-allusive, c'est-à-dire s'il **propage un préjugé sur la culpabilité ou une conviction au lieu de se limiter à une description des faits**.

- SECTION 2 : LES LIMITES INTRINSEQUES DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE : LE CONSENTEMENT DE LA PERSONNE

S'agissant spécifiquement du droit au respect de la vie privée et du droit à l'usage, il faut avoir à l'esprit que certaines informations et comportements qui pourraient être constitutifs d'atteinte à la vie privée mais, ne le sont pas si la personne a donné son consentement à la divulgation ou à la reproduction de son image. En effet, le droit au respect de la vie privée c'est un droit personnel, qui protège la personne et donc, la **personne est libre de renoncer à cette protection**. Elle peut révéler elle-même des informations sur sa vie privée, ou si elle autorise la divulgation de certaines informations.

C'est un **double-consentement qui est exigé**, il faut **l'autorisation de recueillir les informations privées par la personne**, et **l'autorisation de les divulguer**. Le fait d'autoriser quelqu'un à prendre une photo de soi ne vaut pas autorisation de diffuser l'image.

Pour ces atteintes licites à la vie privée, le consentement qui est donné, peut être verbalisé ou tacite, à condition dans cette hypothèse, que le consentement ne fasse pas de doute. On ne doit pas déduire le consentement.

Le consentement doit être spécial, c'est-à-dire qu'il vaut pour une finalité déterminée et donc, les tribunaux vont vérifier que la divulgation respecte bien les limites qui ont été fixées par la personne concernée.

L'autorisation qui est donnée, son consentement, comporte souvent une contrepartie monétaire, c'est l'hypothèse des célébrités.

- SECTION 3 : LES LIMITES EXTRINSEQUES DE LA PROTECTION DE L'INTEGRITE MORALE : LA CONFRONTATION AVEC LA LIBERTE D'EXPRESSION

PARAGRAPHE 1 : LE DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE FACE A D'AUTRES DROITS EN CONCURRENCE

Le droit au respect à la vie privée n'est pas un droit absolu (paragraphe 2 de l'article 8 de la CEDH). Il peut y avoir ingérence dans le droit au respect de la vie privée si cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire notamment à la protection des droits et libertés d'autrui. Cela signifie que des atteintes à la vie privée peuvent être licites, justifiées au nom de la protection d'autre droit. Les droits concurrents qui peuvent justifier cette atteinte sont par exemple la liberté d'expression qui inclue le droit à l'information ; le droit à la sécurité ; l'ordre public ; le droit à la preuve etc.

Concernant la liberté d'expression plus spécifiquement, c'est une liberté constitutionnelle protégée par l'article 11 de la DDHC et par l'article 10 de la CEDH. La liberté d'expression comprend la liberté de la presse, d'opinion et la liberté de recevoir ou communiquer des informations ou des idées. Ce n'est pas seulement la liberté de s'exprimer mais aussi que quelqu'un d'autre s'exprime. Dans leur rôle d'information, les médias peuvent être conduits à divulguer des éléments qui relèvent de la vie privée de certaines personnes voire, des photographies ou images pour illustrer les informations qui délivrent, considérées comme légitimes. Si la personne concernée considère qu'elle est victime d'une atteinte à sa vie privée et donc, qu'elle agit en justice, le juge va être tenu de trancher un conflit entre 2 droits qui sont d'égale valeur : la liberté d'expression et le droit au respect de la vie privée. Le juge va devoir opérer une mise en balance entre ces droits pour trouver un équilibre entre les intérêts en cause qui s'affrontent. Pour cela, il va utiliser la méthode de **la balance des intérêts** qui est celle utilisée par la Cour Européenne des droits de l'Homme. L'arrêt du 10 novembre 2015 de la Cour Européenne des droits de l'Homme, l'arrêt Couderc et Hachette Filipacchi associés contre France ont exposé cette méthode. En 2005, une dame avait fourni au magazine Paris match déclarant que son enfant était celui du Prince Albert (Prince de Monaco). Il saisit les juges français et invoque une atteinte à la vie privée et au droit à l'image. Les juges lui donnent raison mais, la société d'édition a saisi la CEDH car, cela portait atteinte à la liberté d'expression. La Cour a condamné la France et a considéré que cette décision, par laquelle on avait condamné la société d'édition, portait effectivement atteinte à la liberté d'expression car, les informations publiées par le magazine pouvaient être considérées comme participant à un débat d'intérêt général et donc, que ceux sont des informations qui pouvaient légitimement intéresser le public. Selon la Cour, l'atteinte commise par l'édition n'était pas disproportionnée par rapport au droit à l'information du public. La protection de l'intégrité morale peut se confronter à d'autres droits et libertés fondamentales.

Les juridictions françaises sont très attentives à opérer attentivement cette balance. Globalement, lorsque les informations divulguées s'inscrivent dans le cadre d'un débat d'intérêt général ou dans un événement d'actualité, on constate que la protection de la vie privée est un peu amoindrie, pèse moins lourd dans la balance, face au droit à protection à la vie privée. Les juges vérifient si la publication qui porte atteinte à la vie privée n'excède pas ce qui est nécessaire pour informer le public. On vérifie s'il n'y a pas une recherche de sensationnel etc. L'arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2019, n°18-21.871 relate aussi cette balance entre droit à la protection de la vie privée et à l'information.

PARAGRAPHE 2 : LE DROIT A LA DIGNITE : UNE LIMITE INFRANCHISSABLE ?

A. LE DROIT A LA DIGNITE, UNE LIMITE TRADITIONNELLEMENT RETENUE

La participation à un débat d'intérêt général n'autorise pas les journalistes à ne pas respecter certaines limites et, il y a 1 limite qui a été longtemps considérée **comme infranchissable**, c'est le **droit à la dignité**. De façon classique, on considère que la dignité est un rempart ultime face à la liberté d'expression. Souvent, les juges ont rappelé une formule selon laquelle « *la liberté de la presse et le droit à l'information du public autorise la diffusion de l'image de personnes impliquées dans un événement d'actualité où, illustrant avec pertinence un débat d'intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine* ». 2 arrêts illustrent ce principe. L'arrêt de la 1^e Chambre civile du 20 décembre 2000, n°98-13.875 qui concernait l'assassinat du préfet Erignac à la suite duquel le magazine Paris Match avait publié des photos du corps du préfet après son assassinat, on le voyait allongé sur la chaussée, décédé. Les juges ont considéré que la publication était illicite car elle portait atteinte à la dignité de la personne. L'arrêt de la 1^e chambre civile du 20 février 2001 : c'était une publication dans un journal qui relatait l'attentat du RER B en 1995 et, ils avaient joint des photos des victimes etc. Les juges ont de nouveau cité le principe énoncé précédemment. Enfin, l'arrêt de la CEDH du 25 février 2016 requête n°4683/11 : il s'agissait d'un magazine qui avait consacré un dossier à l'affaire Ilan Halimi qui était un jeune homme qui avait été tué par « le gang des barbares ». Il avait subi des actes de tortures au moment de son assassinat et, Paris Match avait publié des photos choquantes avant qu'il soit décédé. La famille a saisi les juridictions françaises qui avaient ordonné le retrait de certaines photos. La maison d'édition a formé un recours devant la liberté des droits de l'Homme car cela formait une atteinte à la liberté d'expression ; la Cour européenne a considéré que, en l'espèce, la restriction à la liberté d'expression était proportionnée et, a donné raison aux juges français.

Dans ces jurisprudences, on est en balance la liberté d'expression face à d'autres droits et, il y a un rempart ultime : la dignité des personnes.

Le **principe de dignité peut aussi restreindre la liberté de réunion**, on peut citer les nombreuses décisions qui ont concerné **l'humoriste Dieu donné** car, ce dernier a plusieurs fois vu ses spectacles interdits par des décisions préfectorales par rapport au contenu de son spectacle car, ils considéraient que certains propos étaient de nature à provoquer la haine, la discrimination raciale etc. Les juridictions administratives (Conseil d'Etat etc.) valident généralement ces interdictions de spectacles car, ce comportement est susceptible de porter

atteinte à la dignité humaine. L'idée est de dire que, par ses propos et ses gestes, Dieu donné porte atteinte à la dignité humaine qui est une composante à l'ordre public et donc, on peut lui ordonner de ne pas tenir ses spectacles. Dans ce cas-là, on porte atteinte à la liberté de réunion et d'expression, en faisant valoir le droit à la dignité.

Éric Zemmour a aussi parfois été condamné pour des propos islamophobes et racistes, la décision du 17 septembre 2019 de la Cour de cassation le démontre.

B. LE DROIT A LA DIGNITE, UNE LIMITE AUJOURD'HUI DISCUTEE ?

En 2019, la Cour de cassation a rendu une décision en assemblée plénière qui a semé le trouble concernant la question de savoir si la dignité constitue vraiment un rempart infranchissable face à la liberté d'expression. C'est un arrêt du 25 octobre 2019, n°17-86.605, l'affaire concernait la diffusion, pendant l'émission « On n'est pas couché », d'une affiche parodique qui avait été publiée dans Charlie Hebdo, qui représentait Marine Le Pen, alors aux élections présidentielles sous la forme d'un excrément avec une mention « c'est la candidate qui vous ressemble ». Marine Le Pen a agi en justice et a considéré que c'était une injure publique à son égard. Le débat portait sur la question de savoir si cette publication portait atteinte à sa dignité. Les juges ont considéré que l'animateur devait être relaxé car il n'avait pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression et, pour dégager cette décision, ils se sont fondés sur le ton satirique du journal, sur le contexte électoral et, sur le fait qu'il n'y avait pas d'attaque personnelle car d'autres candidats avaient aussi subi. Dans l'arrêt, on relève une formule étonnante, les juges énoncent que « *la dignité ne saurait être érigée en fondement autonome des restrictions à la liberté d'expression* » : la Cour de cassation semble ici énoncer que la dignité n'est pas une exception à la liberté d'expression et, c'est la première fois que la Cour se positionne de cette façon. Cela renforce encore la liberté d'expression dans notre pays. Il faudra attendre les décisions ultérieures pour savoir si c'est un revirement de jurisprudence ou, si la solution s'explique seulement par les faits en question.

La Cour d'appel de Paris a rendu une décision le 16 juin 2021, n°20-01.355, l'affaire concernait l'exposition « L'infamille » dans laquelle l'artiste exposait des lettres choquantes. Une association a assigné l'organisateur de l'exposition et a agi contre lui, en invoquant une atteinte portée à la dignité humaine. L'affaire est montée jusqu'en Cour de cassation et, cet arrêt et l'arrêt de la Cour d'appel de renvoi, il fait suite à la décision de la Cour de cassation. Dans sa décision, la Cour d'appel cite expressément l'arrêt de 2019 (Marine Le Pen) et, rappelle que l'atteinte à la dignité ne peut constituer un fondement autonome de restriction à la liberté d'expression.

On peut comprendre de ces arrêts que, le principe de dignité constitue une limite à la liberté d'expression, seulement quand il est confronté à d'autres intérêts en présence comme le droit au respect à la vie privée, mais pas lorsqu'il est invoqué seul. En l'espèce, l'association n'invoquait que l'atteinte à la dignité et pas à d'autres droits et, c'est probablement ce qui a conduit les juges à considérer que l'atteinte à la dignité ne suffisait pas. La Cour de cassation vient nous dire que le principe de dignité n'est pas une limite autonome à la liberté d'expression.

THEME 5 : LA PROTECTION DES MAJEURS

• INTRODUCTION

Pendant longtemps, on appelait cette partie du cours, le droit des « incapacités », les personnes qui sont juridiquement dites incapables. Progressivement, cette expression « d'incapable » a été retirée des textes, aujourd'hui on parle de la protection des personnes vulnérables. Ce terme d'incapacité n'a pas entièrement disparu. Même si au sens commun, le terme d'incapacité semble être négatif, au sens juridique, il correspond bien.

Aujourd'hui, on parle de majeurs protégés et pas de personnes incapables. Néanmoins, la **personne vulnérable protégée est frappée d'une incapacité juridique.**

PARAGRAPHE 1 : LA DEFINITION DE LA CAPACITE JURIDIQUE

La **capacité juridique c'est l'aptitude d'une personne à être sujet de droit et d'obligation, c'est-à-dire, l'aptitude à acquérir des droits et à les exercer.** C'est donc un **attribut** de la personnalité juridique. Parmi les personnes au sens juridique, certaines peuvent être privées de tout ou partie de ses aptitudes, on va leur dénier leur capacité juridique pour exercer certains droits par rapport à leur vulnérabilité. On s'aperçoit que la vulnérabilité des personnes a donc des effets sur la situation juridique de la personne. Pour bien comprendre ce régime d'incapacité, il faut comprendre la distinction entre capacité de jouissance et d'exercice.

La capacité juridique comprend 2 aspects :

- d'un **côté la capacité de jouissance** c'est-à-dire l'aptitude à acquérir un droit, à en être titulaire
- la **capacité d'exercice** qui est l'aptitude à exercer les droits dont on est titulaires.

A. LA CAPACITE DE JOUISSANCE

La capacité de jouissance est l'aptitude à être titulaire de droit. A l'inverse, **l'incapacité de jouissance c'est l'aptitude à être sujet de droit.** L'incapacité de jouissance est une mesure très grave, il faut comprendre qu'il n'y a jamais d'incapacité de jouissance générale qui soit prononcée car, cela reviendrait à nier la personnalité juridique de la personne qui se définit comme la capacité à être titulaire de droit. Les incapacités de jouissance sont toujours **circonsrites à certains droits** et elles privent la personne qui en est frappée, de certains droits ou de certaines activités. Les incapacités de jouissance sont très rares en droit civil, on a l'exemple de l'article 904 du code civil qui **interdit aux mineurs de moins de 16 ans de faire un testament** ou une **donation**. On a d'autres exemples qui ont pour objectif d'**éviter les captations** (détournement) **d'héritage**, c'est l'article 909 du code civil qui interdit aux médecins de recevoir un bien en vertu d'une donation ou d'un testament consenti par l'un de ses patients au cours d'une maladie dont il est décédé. Il y a également l'article 1116-4 du code de l'action sociale et des familles qui interdit aux personnes du personnel des maisons de

retraites ou des établissements psychiatriques de se porter acquéreurs des biens qui se seraient vendues par les personnes vulnérables.

Ces incapacités de jouissance sont des interdictions qui portent atteinte à la capacité de la personne et doivent être entendues de façon stricte. Récemment, le Conseil constitutionnel a partiellement censuré l'article 1116-4 du code de l'action sociale et des familles car, cet article interdisait aussi aux personnes dépendantes de faire des dons aux personnes qui leur apportent des services à la personne à domicile contre rémunération. Cela est une atteinte au droit de propriété de la personne. Cette interdiction a été jugée inconstitutionnelle car, selon le Conseil constitutionnel, elle portait une atteinte disproportionnée à l'objectif de protection qui était poursuivi, c'est la décision du 12 mars 2021 du Conseil constitutionnel, provenant de la QPC 2020-888. Cela est encore une mise en balance entre un droit et, ici un objectif.

En dehors de ces quelques cas d'incapacités de jouissance qui sont prévues dans le code civil, le principe est que chacun dispose d'une capacité de jouissance générale et absolue.

C'est une mesure de protection et, si on est protégée c'est la preuve qu'on est titulaire de droit.

B. LA CAPACITÉ D'EXERCICE

La capacité d'exercice et la faculté pour la personne qui est titulaire de droit de pouvoir les exercer librement et individuellement. A contrario, **l'incapacité d'exercice c'est l'incapacité de la personne à faire valoir par elle-même dans la vie juridique à exercer librement le droit dont elle est titulaire**. Dans l'incapacité d'exercice, le droit que l'individu ne peut pas exercer seul **pourra être accompli pour son compte par un tiers**, par son représentant.

Il y a 2 types d'incapacités d'exercice, 2 motifs :

- **L'incapacité liée à l'âge**, cela concerne le **mineur** car, le mineur de -18 ans est incapable de faire exercer ses droits, c'est une incapacité de plein droit. On est titulaire de droit mais, on ne les exerce pas soi-même.
- **L'incapacité liée à une altération des facultés mentales** c'est-à-dire que, à partir de la majorité (ou de l'émancipation), on obtient la capacité d'exercice, cela est précisé à l'article 414 du Code civil qui dispose que « **la majorité est fixée à 18 ans accomplie, à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance** ». Cela signifie qu'à partir de la majorité, la capacité d'exercice c'est la règle pour les majeurs et, **seule la constatation judiciaire d'une atteinte des facultés mentales ou physiques de la personne permet de déroger** à ce principe général de **la capacité d'exercice de la personne physique majeure**. La personne majeure qui est victime d'une altération de ses facultés mentales pourra alors faire **l'objet d'une mesure de protection**.

Les articles 1145 et 1146 du code civil concerne les contrats d'obligations.

PARAGRAPHE 2 : LES SOURCES PRINCIPALES DU DROIT DES PERSONNES VULNERABLES

Il n'y a pas une partie précise du code civil qui soit consacrée à la protection des personnes vulnérables. En réalité, elle s'opère par le biais de plusieurs institutions que l'on retrouve par exemple au titre 9 du livre 1^e du code civil sur l'autorité parentale ; au titre 10 du code civil qui concerne la minorité ; au titre 11 qui concerne la majorité et les majeurs protégés par la loi. On trouve aussi des textes sur la capacité dans le droit des contrats par exemple (1145, 1446). Enfin, le droit des majeurs vulnérables a aussi des liens étroits avec le droit de la famille car, les organes de protections du majeur vulnérable sont choisis en priorité au sein de la famille.

SOUS-THEME 1 : LA PROTECTION PONCTUELLE DU MAJEUR INDEPENDAMMENT DE L'OUVERTURE D'UNE MESURE JURIDIQUE DE PROTECTION

La protection d'une personne majeure peut être occasionnelle, ponctuelle sans que soit ouverte forcément une mesure de protection juridique. Cette protection peut être mise en place par le biais d'une habilitation judiciaire (section 1) ou par le biais d'une action en nullité des actes qui ont été passés (section 2).

- SECTION 1 : LA REPRESENTATION DANS LE CADRE DU COUPLE MARIE (L'HABILITATION JUDICIAIRE)

Il existe des mécanismes qui permettent, quand une personne est hors d'état de manifester sa volonté, de la faire représenter par son conjoint si elle est mariée, pour les actes qui nécessitent leur consentement conjoint, aux deux époux. L'article 217 du Code civil expose que l'époux de celui qui est hors d'état de manifester sa volonté, va demander au juge l'autorisation d'effectuer seul un acte, de prendre seules des décisions pour lesquelles le consentement de son conjoint aurait été requis, par exemple, vendre un bien commun ou décisions importantes relatives aux enfants. Une infirmité, une absence prolongée, une altération des facultés mentales, liée à la démographie ou, si cela va contre l'intérêt de la famille sont toutes des conditions de cette autorisation. Cette autorisation sur le fondement de l'article 217 du code civil ne peut pas être requise pour une décision qui n'appartenait qu'à l'autre époux.

A côté de l'article 217, il y a un autre mécanisme qui est la représentation judiciaire prévue à l'article 219 du code civil « *Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habilitier par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.* »

L'article 219 est plus large car il permet à l'époux représentant de représenter l'époux « incapable » de s'exprimer même pour des actes qui lui appartiennent exclusivement donc, même pour des actes pour lesquels l'époux représentant n'a aucun pouvoir à l'origine (l'hypothèse des biens personnels du conjoint qui est incapable de s'exprimer).

- SECTION 2 : L'ACTION EN NULLITE D'UN ACTE PASSE SOUS L'EMPRISE D'UN TROUBLE MENTAL

Cette seconde protection ponctuelle découle de l'article 414-1 du code civil qui dispose que « ***pour faire un acte valable il faut être saint d'esprit*** » et donc, cette disposition permet à toute personne ayant réalisé un acte alors qu'elle était sous l'emprise d'un trouble mental d'en demander la nullité même si cette personne ne fait pas l'objet d'une mesure de protection spécifique.

SOUS-THEME 2 : LA PROTECTION DURABLE DES MAJEURS VULNERABLES

- SECTION 1 : ELEMENT D'INTRODUCTION ET DISTINCTION ENTRE LA PROTECTION DE LA PERSONNE ELLE-MÊME ET LA PROTECTION DE SON PATRIMOINE

Pour les majeurs qui sont atteints dans leur faculté intellectuelle ou mentale, leur vulnérabilité peut justifier des mesures de protection juridique qui vont amoindrir leur propre capacité d'exercice. Ces mesures sont encadrées par des principes fondamentaux comme **le respect de la liberté individuelle**, qui témoignent de l'idée selon laquelle, **l'incapacité est une exception** et, il faut toujours essayer de tenir compte de la volonté de la personne quand c'est possible, même pour les majeurs les plus atteints.

Les **mesures de protection juridique** que l'on peut adopter pour un majeur vulnérable sont nombreuses :

- Le mandat de protection future
- L'habilitation familiale
- La sauvegarde de justice
- La curatelle
- La tutelle

Ces mesures **alternatives** vont être mises en place quand on va constater qu'une personne majeure fait l'objet d'une altération de ces facultés mentales et donc, qu'elle **n'est plus en mesure d'effectuer certains actes seule** ou, quand elle **n'est plus en mesure de défendre ses intérêts**. Selon son niveau d'autonomie et sa faculté de discernement, la mesure prononcée sera plus ou moins contraignante et, lui laissera plus ou moins d'autonomie pour agir par lui-même dans la vie juridique.

Ces mesures de protection juridique ont pour but de **protéger d'un côté la personne elle-même**, par exemple pour des décisions médicales ; mais elles ont aussi pour but de **protéger son patrimoine**. Ces mesures de protection présentent une **dualité d'objet** qui a été affirmée

de façon très nette par la loi du 5 mars 2007 car, elle pose le principe que la protection ne concerne pas seulement les biens de la personne mais concerne aussi la personne elle-même. On retrouve cette dualité dans les articles 415 du code civil « *Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre* » et l'article 425, alinéa 2 du code civil « *S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.* »

C'est important de comprendre cette dualité car, les règles et les principes qui gouvernent ces 2 aspects (protection de la personne et des biens), sont différents.

PARAGRAPHE 1 : LA PROTECTION DU PATRIMOINE : UNE PROTECTION POUR LA CONCLUSION D'ACTE QUI ENGAGE LE PATRIMOINE DU MAJEUR

Les majeurs vulnérables sont plus ou moins inaptes selon le degré d'atteinte à leur faculté mentale. C'est ce **degré d'atteinte qui détermine la mise en place de régime de protection qui sont différents.**

A. DIFFERENTES MODALITES D'ACCOMPAGNEMENT : ASSISTANCE, REPRESENTATION OU AUTORISATION

Selon la nature de l'acte à accomplir, et selon les facultés personnelles du majeur qui fait l'objet d'une protection, les techniques utilisées vont être différentes :

- **La représentation** : les **incapacités les plus graves** ont pour palliatif spécifique la représentation. Dans cette hypothèse, l'incapable (majeur protégé) **ne figure pas en personne sur la scène juridique** ; il **n'émet pas lui-même la volonté** qui va former le contrat, il ne signe pas lui-même l'acte. La loi lui attribue un représentant qui va agir en son nom et pour son compte. C'est le cas des **mineurs non émancipés** par ses **parents** ou un administrateur légal ; et du **majeur sous tutelle** qui est **représenté par un tuteur**. Les mécanismes de représentation sont dans les hypothèses des incapacités les plus importantes.
- **L'assistance** : c'est un procédé plus souple qui permet à **l'incapable d'agir lui-même mais, à condition d'être assisté**, d'être **conseillé** par un **tiers** qui va être présent, à ses côtés. C'est typiquement le procédé qui est appliqué aux **majeurs sous curatelle**. L'incapable reste à la tête de ses affaires et, la loi lui impose seulement d'avoir à ses côtés, sur la scène juridique, une personne avisée qui interviendra avec elle pour compléter une capacité qui est dite imparfaite. Dans les mécanismes d'assistance comme la curatelle, la **volonté personnelle du majeur protégé est nécessaire à la formation de l'acte juridique** mais, la personne chargée de la protéger doit approuver les actes qu'elle souhaite passer et signer avec elle.
- **L'autorisation** : on se rapproche du mécanisme de l'assistance mais, dans ce mécanisme, c'est un **mécanisme qui implique d'avoir l'accord préalable d'une autre autorité** comme le juge des tutelles, appelé aujourd'hui juge des contentieux et de la protection. Cette

autorisation permettra ensuite au majeur protégé d'agir seul. Le **système de l'autorisation** peut, et le plus souvent, se **superpose à celui de la représentation** car, pour certains actes, le représentant légal/le tuteur, va devoir demander une autorisation préalable, c'est le cas pour les **actes dits de dispositions** : les actes les plus graves, qui engagent le plus son patrimoine.

B. UNE REPARTITION DES POUVOIRS EN FONCTION DE LA NATURE DES ACTES CONCERNEES

Pour comprendre les mécanismes de protection des majeurs, il faut comprendre la notion de pouvoir qui est différente de celle de capacité. Le **pouvoir** c'est **l'aptitude à exercer les droits d'autrui, l'aptitude à agir pour le compte d'autrui et en son nom**. Quand un majeur est protégé, par exemple quand il est représenté, son tuteur/représentant va avoir certains pouvoirs. Les pouvoirs du représentant vont dépendre de l'acte dont il s'agit. Il va donc falloir distinguer selon la nature de l'acte en question, qualifier l'acte pour pouvoir déterminer à la fois ce que peut faire le majeur protégé et, ce que peut faire ou non son représentant. Plus l'acte est grave (donation d'une partie du patrimoine d'un majeur protégé), plus le besoin de protection est important. La loi utilise une **distinction entre les actes conservatoires, les actes d'administration** et les **actes de dispositions** pour délimiter les pouvoirs respectifs du majeur protégé, de l'assistant, du représentant ou du juge. Cette triple distinction est un véritable guide des pouvoirs. Il est important de comprendre ces différentes notions car, selon la nature de l'acte, cela change.

Depuis la réforme du 5 juin 2007, pour éviter des discussions sans fin sur la nature des actes, une classification des actes a été opérée par décret. Le décret du 22 décembre 2008 donne des **définitions générales** et comprend **2 listes** en annexes qui **permettent de qualifier les actes**. Ces listes sont reproduites après l'article 496 du code civil.

1. LES ACTES CONSERVATOIRES

L'article 3 du décret du 22 décembre 2008 définit les actes conservatoires comme « **les actes qui permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable ; sans compromettre aucune prérogative du propriétaire** ». L'acte conservatoire est le moins grave dans la hiérarchie des actes. Les actes conservatoires ont pour seul effet de maintenir les droits de la personne, de les consolider ou d'éviter qu'ils soient perdus par l'accomplissement de formalités (ex : payer une facture d'assurance). La règle est donc que le majeur protégé peut toujours prendre des décisions pour effectuer des actes conservatoires car ceux sont les moins graves.

2. LES ACTES D'ADMINISTRATION

La définition des actes d'administration est dans l'article 1^e du décret du 22 décembre 2008 « **constituent des actes d'administration les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée, dénuée de risque anormal** ». Les actes d'administrations sont les **actes nécessaires à la gestion courante d'un bien, qui permettent de le faire**

fructifier, de le conserver sans en compromettre la valeur en capital. C'est un acte de mise en valeur, d'exploitation normal du patrimoine. Ceux sont les actes qu'un propriétaire a l'habitude de faire pour la gestion de son bien. Le **premier tableau** évoque de façon **incontestable** les actes d'administration, par exemple, la location de son appartement, vendre des récoltes, souscrire un contrat d'assurance ou encore demander une carte de retrait. Le **second tableau** évoque les actes d'administration, ceux qui sont **présumés** actes d'administrations mais peuvent, sous certaines conditions être des actes de disposition : c'est notamment le cas pour la conclusion et la rupture d'un contrat de travail en tant qu'employeur ou salariés.

3. LES ACTES DE DISPOSITION

Les actes de dispositions sont d'après le décret du 22 décembre 2008 « **les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capitale ou une altération des prérogatives de son titulaires** ». L'acte de disposition est celui qui est présenté comme le plus grave. **C'est une opération qui entame/engage le patrimoine du majeur et**, si on se réfère aux 2 annexes du décret de 2008, on a 2 listes. La **première liste annexée** liste les **actes qui sont considérés quelques soient les circonstances** comme des actes de disposition, par exemple la vente d'un bien immobilier, les donations, la demande d'une carte bancaire de crédit, la clôture d'un compte en banque, le changement de régime matrimonial etc. Dans le **deuxième tableau**, on a une **liste d'actes qui sont présumés** être des actes de dispositions, **selon les circonstances**. Cela **ouvre la possibilité de contester** cette présomption. L'emprunt ou le prêt d'une somme d'argent sont des exemples d'actes de dispositions présumés.

Quelles sont les pouvoirs du majeur et de la personne chargée de la protection pour chacun de ces actes ?

Ces actes vont du moins grave au plus grave (actes conservatoires < actes d'administration < actes de disposition), les pouvoirs du majeur protégé et de celui qui est chargé de la protection vont dépendre de ces actes.

- Pour les actes conservatoires, les actes les moins graves, le **principe est que le majeur protégé peut toujours les faire seul. Ils ont la capacité d'exercice.**
- Pour les actes d'administrations, **tout dépend du degré de protection auquel est soumis le majeur protégé.**
- Pour les **actes de dispositions**, les actes les plus graves, le **principe est qu'ils ne peuvent pas être réalisés par le majeur protégé tout seul** : il devra être soit assisté soit représenté en fonction de la mesure de protection. Ils n'ont **pas la capacité d'exercice.**

PARAGRAPHE 2 : LES PRINCIPES GENERAUX CONCERNANT LA PROTECTION DE LA PERSONNE ELLE-MÊME ET, DESTINES A GARANTIR LE RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX

Les règles qui sont relatives à la personne elle-même, démontrent **une volonté de préserver son autonomie** pour des questions qui relèvent en grande partie de son **intimité**. La réforme du 5 mars 2007 a fait de la protection de la personne majeur l'un des objectifs principaux du dispositif et, l'idée générale est que la protection judiciaire a des effets beaucoup plus diffus en matière personnelle qu'en matière patrimoniale car il ne s'agit pas ici d'éviter une dilapidation de ses revenus mais plutôt de **respecter sa volonté, sa dignité**. Le but va être de **trouver un équilibre entre autonomie de la personne protégée et besoins de protection**. Cette autonomie, on cherche à l'atteindre par des mécanismes d'informations du majeur qui ont pour objectif de lui permettre de prendre des décisions en toutes connaissances de cause en matière personnelle.

A. LE DROIT A L'INFORMATION DE LA PERSONNE PROTEGEE

Pour assurer le respect des droits fondamentaux de la personne protégée, il existe d'abord un devoir d'information à la charge de celui qui est chargé de la protection : c'est l'article 457-1 du code civil « **La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part** ». La personne protégée a un droit à une information claire, compréhensible, adaptée à son niveau de compréhension ; qui va évoquer la procédure de mise sous protection, ses motifs, son contenu etc. La personne protégée devra être informée.

B. L'AUTONOMIE DU MAJEUR PROTEGE POUR LES DECISIONS PERSONNELLES

Le majeur qui bénéficie d'une mesure de protection **agit en principe seul dans le domaine personnel**. Les **actes personnels relèvent en principe du pouvoir de la volonté** de l'individu protégé. En principe, personne ne peut accomplir pour le majeur protégé des actes considérés comme personnels. La loi opère une distinction entre les **actes strictement personnels** (article 458 du code civil) et les décisions relatives à la personne du majeur (article 459 du code civil).

1. LES ACTES STRICTEMENT PERSONNELS

Les actes strictement personnels sont évoqués dans l'article 458 alinéa 1 du code civil : « **Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée** ». Il y a un certain nombre d'actes qui ne peuvent être réalisés que par la personne elle-même, sans possibilité d'être représenté ou assisté. Une liste est donnée à cet article qui concerne la curatelle ou la tutelle mais, les articles 414-6 et 469 renvoient à cet article 458. La liste de l'article 458 alinéa 2 dispose que « **Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant** ». Il y a dans cette liste tous les actes qui concernent l'enfant de la

personne. Cependant, il faut bien comprendre que la liste de cet article n'est pas limitative, elle n'est pas exhaustive. Il **y a d'autres actes que ceux qui sont listés dans cet article**, qui **peuvent être considérés comme des actes strictement personnels**, par exemple la décision d'accoucher sous X pour une femme, ou la question du mariage de la personne protégée, du moins, son consentement au mariage. La loi du 23 mars 2019 a **modifié l'article 460 du code civil** car, jusqu'à 2019, la personne protégée devait demander une autorisation pour se marier et, depuis 2019, le majeur protégé qui souhaite se marier doit simplement informer la personne qui est chargée de sa protection et, celle-ci aura un droit d'opposition au mariage. C'est un **acte strictement personnel** qui implique que **la personne seule peut le faire**. L'arrêt du 2 décembre 2015 n°14-25.777 de la Cour de cassation expose cette idée : dans cet arrêt la cour a énoncé que le mariage est un acte strictement personnel et donc seul le majeur protégé pouvait demander au juge l'autorisation (avant 2019) mais la personne qui le protège non. L'article 461 du code civil dit que le **PACS est un acte strictement personnel**.

2. LES DECISIONS RELATIVES A LA PERSONNE

Pour les décisions qui concernent la personne elle-même mais qui ne relèvent pas de la catégorie des actes strictement personnels (vu au-dessus), l'article 459 alinéa 1 du code civil énonce le principe selon lequel le majeur prend ces décisions seul « **dans la mesure où son état le permet** ». Ce **n'est que si son état ne lui permet pas de prendre une décision, seul** de façon éclairée qu'une **protection pourra être mise en place également pour les décisions relatives à sa personne**. On pourra mettre en place soit une assistance, soit une représentation pour ces décisions personnelles.

La loi de programmation du 23 mars 2019 a apporté des modifications à la question de savoir si le majeur protégé conserve ou non son droit de vote. Jusqu'en 2019, c'était le juge des contentieux et de la protection = juge des tutelles, quand il ordonnait une mesure de protection, qui statuait sur le maintien ou non du droit de vote de la personne protégée. Depuis **2019, les personnes protégées conservent d'office leur droit de vote** et, même si le majeur protégé ferait l'objet d'une représentation pour les décisions personnelles, le tuteur n'a pas le pouvoir de voter à la place de la personne protégée.

Il y a d'autres exemples de décisions relatives à la personne comme la question du **choix de la résidence**, ses **relations personnelles** etc. qui sont exposés dans l'article 459-2 du code civil. Une décision de la Cour de cassation 1^e chambre civile du 24 juin 2020 n°19-15.781 concernait une dame sous tutelle et, on avait interdit à son frère tout droit de visite : on se pose la question du libre choix de ses visites.